

Hasta los hebreos, cuyo monoteísmo era, en rigor, incompatible con la religión romana, supieron practicar entre las poblaciones de la capital un hábil proselitismo, de modo que a comienzos del Principado eran muchos los que alternaban con los otros cultos el del dios de Israel.

Sin embargo, alguna antigua ley que prohibía a los ciudadanos practicar cultos no reconocidos por la autoridad pública, se conocía todavía en la época de Cicerón, o por lo menos se consideraba que había existido (cfr. Cicerón, *de leg.* 2, 8, 19); en la época imperial la tradición fué retomada, aparte que para suprimir supersticiones aborrecidas y artes mágicas, también, y en amplísima escala, para la persecución del cristianismo. Es sabido, por lo demás, que las persecuciones no fueron suscitadas por motivos puramente religiosos, sino principalmente por el conflicto irreducible entre la enseñanza de Cristo y la concepción romana del imperio, y, como expresión práctica de este conflicto, por la resistencia pertinaz que los cristianos oponían a la orden de sacrificar al emperador y de jurar sobre su majestad. De todas maneras, tampoco la áspera lucha contra la nueva religión tuvo reflejos sobre la capacidad jurídica.

Estos se vieron, en cambio, después del triunfo del cristianismo, implícito en el Edicto Constantिनiano, del 313. En el derecho justinianeo, que lleva a término la evolución legislativa de los dos siglos precedentes, los ciudadanos que por motivos religiosos son colocados en condiciones inferiores se distinguen en tres grupos: los paganos y hebreos; los apóstatas y heréticos, y por último, más gravemente perseguidos, los maniqueos. Los paganos y hebreos son atacados sobre todo en sus derechos políticos, en cuanto se los excluye, en general, de los cargos y oficios; los hebreos no pueden, además, tener esclavos cristianos ni contraer matrimonio con personas de esta religión. Para los apóstatas (cristianos convertidos en paganos o hebreos) y heréticos, a la exclusión de los cargos se agregó la incapacidad para testar y donar: la herencia de los apóstatas queda para los herederos legítimos, la de los heréticos parece que fuera al fisco. El maniqueísmo, en fin, es castigado como delito: aparte de la capacidad para donar y para testar, se les quitó a los secuaces de esta herejía también la de recibir herencias y legados y de contratar a cualquier título, y respecto de los esclavos se consideró hecho lícito abandonarlos para servir a un patrón ortodoxo.

6) La pertenencia a determinadas *clases o estados o profesiones* da también lugar a múltiples consecuencias en materia de capacidad. Recordemos ante todo la antigua contraposición de la plebe al patriciado, la que, aparte de las consecuencias de derecho público, implicaba también la prohibición de nupcias entre los dos órdenes de ciudadanos; la prohibición fué abolida, según la tradición, por una *lex Canuleia* del 445 a. C. Recordemos también, aunque no tenga importancia para el derecho privado, el diverso tratamiento que en materia de derecho criminal se dispensa desde comienzos del Principado a los *humiliores* respecto de los *honestiores*. Más interesante es señalar que en materia de derecho privado se presentan, ora como privilegiados, ora como sujetos a particulares restricciones, los senadores, los magistrados provinciales y su séquito, los militares. A los primeros, por ejemplo, les está prohibido por la *lex Claudia* del 218 a. C., y sucesivamente por la legislación Augustea, poseer naves; se les impone invertir en fundos itálicos por lo menos una cuarta parte del patrimonio y se les prohíben las nupcias con libertinas, etc.; a los segundos se les prohíbe manumitir a los propios esclavos en la provincia, tomar allí mujer, recibir obsequios o adquirir bienes inmuebles en el lugar; a los soldados, en fin, mientras se les conceden grandes privilegios en materia de testamento y de capacidad patrimonial cuando son hijos de familia, se les prohíbe — por lo menos en la época clásica — el matrimonio y la manumisión de los esclavos.

Pero un verdadero régimen de castas se pone en práctica en el derecho romano-helénico. Se forman, en efecto, en esta época, corporaciones hereditarias de oficios, de las cuales el particular no puede salir sin incurrir en graves penas; y sobre todo los obremos afectados a las oficinas del Estado están en condición semi-servil, tanto que un escritor eclesiástico (EUSEBIO, *vita Constant.*, II, 34) los llama *οἰκῆται τοῦ ταμείου* (*servi fisci*). Por otra parte, no es ésta sino una de las aplicaciones de la concepción económica y política bizantina, que reparte la población en tantos círculos cerrados, imponiendo a uno las cargas de la administración local y la responsabilidad por los impuestos de cada ciudad (*ordo decurionum*), al otro la defensa militar del Imperio, y así sucesivamente hasta el último de los oficios.

La expresión más notable del fenómeno señalado está en la institución del *colonato*, o — como ya los padres de la Iglesia lo

llamaban— servidumbre de la gleba. Sus orígenes son bastante complejos, y no todos los estadios del desenvolvimiento pueden definirse con seguridad; parece, en particular, que a esta institución, igualmente difundida en la época justiniana por todas partes del Imperio, se hubiera llegado a través de fases que varían según las provincias. En Egipto, cuya historia agraria de los primeros siglos de la era vulgar es mejor conocida, encontramos ya desde entonces aplicado, en la práctica administrativa, el vínculo de los cultivadores de terrenos de siembra (terrenos que son todos propiedad del fisco) a su aldea de origen (ἰδία κώμη, o simplemente ἰδία); cuando, desde el siglo III en adelante, la dificultad de percibir los impuestos de la población reducida a la miseria hizo surgir la necesidad de que los grandes propietarios territoriales asumieran la responsabilidad de su ingreso para vastas extensiones, esto no pudo lograrse sino a condición de remachar la cadena al pie de los campesinos sometiéndolos a la servidumbre de los nuevos señores. Análogamente debe haberse desarrollado el colonato en otras provincias helenísticas. En Occidente, en cambio, no hay por qué excluir que el puente de tránsito haya estado representado por la imitación de la institución germánica de los *liti*: clase de origen servil, pero posteriormente liberada, aunque permaneciendo, sin embargo, vinculada a los antiguos patrones, en el sentido de no poder separarse de los fundos a cuyo cultivo estaba afectada. Con ellos se identifican quizá los *inquilini*, de los cuales, con relación a la época de Marco Aurelio en adelante, se habla en nuestras fuentes, y que parecen haber sido precisamente bárbaros establecidos en las distintas provincias para mejorar en ellas la suerte de la agricultura: pese a que no se puede excluir que gozaban del *status libertatis*, se impone, sin embargo, al dueño del fundo la obligación de denunciarlos con ocasión del censo, entre los objetos de su patrimonio (D. 50, 15, 4 § 8), y se admite que éste disponga de ellos por testamento *cum praediis quibus adhaerent* (D. 30, 112 pr.)²¹.

²¹ La genuinidad de los textos citados es, sin embargo, algo incierta, lo que impide señalar con exactitud el límite entre la evolución cumplida en la época clásica y el desarrollo posterior. Y muchos otros puntos de la materia en examen son diversamente discutidos: cfr., por último, SAUMAGNE, *Byzantion*, 12, 1937, ps. 487 y ss., a cuya bibliografía iba agregado el excelente estudio de G. SEGRE, en "Archivio Giuridico", vols. 44 y 46, 1889-1890.

El vínculo del colono con la gleba se afirma decididamente bajo Constantino, especialmente a través de una constitución del 322 (C. Th. 5, 17 [19], 1), que prohíbe al colono abandonar el fundo a que está afectado. En C. 11, 15, 1 (Valentiniano, Teodosio y Arcadio, año 386?) el colonato es definido con las palabras "*lex a maioribus constituta colonos quodam aeternitatis iure detinet, ita ut illis non liceat ex his locis quorum fructu relevantur abscedere, nec ea deserere quae semel colenda susceperunt*". Algunos años después (C. 11, 50, 2, años 395 a 402), se dice que los colonos "*paene est, ut quodam servitute dediti videantur*", y expresiones análogas se repiten varias veces en las constituciones justinianas²².

No les falta, en verdad, a los colonos el *status libertatis*²³; en consecuencia, pueden contraer matrimonio (pero sólo entre colonos, o con los patronos), tener hijos legítimos, contratar y testar; y pueden tener un patrimonio propio, salvo que la enajenación de los bienes esté sujeta al consentimiento previo del patrón, para el cual el patrimonio del colono es garantía por el crédito del canon anual y, eventualmente, medio para cumplir las gravosas obligaciones fiscales. Las limitaciones de la capacidad están todas en función de la dependencia del colono de la suerte del fundo, y lo vinculan no solamente a él, sino también al patrón; en efecto, el colono no puede ser enajenado sin el fundo al que está adscrito, ni retenido cuando el fundo es enajenado; sólo es admitido el cambio entre colonos de varios fundos, del mismo o de distintos propietarios, o que los colonos que sobran en un fundo sean trasferidos a otro del mismo patrón. Corresponde también al patrón un poder disciplinario, pero en los límites del interés del fundo; así, puede fustigar al colono que intente contraer matrimonio con mujer libre, y poner en el cepo al que intente evadirse.

²² Las cuales sancionan, por lo demás, un desarrollo terminológico ya iniciado alrededor del año 400 d. C., por el cual el siervo de la gleba propiamente dicho es llamado *adscripticius*, mientras el nombre de *colonus* es reservado a categorías de trabajadores de la tierra relativamente mejor tratados.

²³ No hay que confundir, en efecto, con los colonos a los *servi adscripti censibus*, o *rustici censitique servi*, aun cuando rijan para ellos disposiciones que los hagan inseparables del fundo: tales disposiciones limitan el derecho del *dominus*, mientras el colonato propiamente dicho limita principalmente la libertad del colono mismo.

Se es colono ante todo por nacimiento. Contra el principio vigente en materia de *status libertatis* y *civitatis*, de que los hijos nacidos de justas nupcias sigan la condición del padre, se estableció una regla nueva y particularmente severa, admitiendo que se entra en la posición del colono si en ella se encuentra también uno solo de los progenitores; si éstos son colonos de distintos patrones, los hijos se dividen entre los dos, con preferencia —si el número es impar— para el patrón de la madre. De otro modo, se puede llegar a ser colono por voluntaria sumisión a un señor, contrato especial que tiene por base una garantía jurada²⁴; por prescripción, es decir, viviendo durante treinta años como tal; por mendicidad, en cuyo caso el nuevo colono es asignado al denunciante; y, en fin, por asignación que el emperador haga de prisioneros bárbaros a tierras públicas o privadas.

El vínculo que liga al colono a la gleba hace que el patrón no pueda liberarlo, como a los esclavos, mediante la manumisión; pero ocurre, en cambio, que el patrón que quiere liberar a un colono le ceda, en todo o en parte, el fundo a que estaba adscrito. Además, el patrón puede liberar al colono ofreciéndolo al servicio militar o al decurionato o a las órdenes sagradas: sólo si llega a ser obispo el colono es libre de derecho, aun sin el consentimiento del patrón.

7) Entre las causas limitativas de la capacidad jurídica estaba comprendido también el sexo. Aparte de la incapacidad política, la mujer no puede en el derecho clásico, y sólo excepcionalmente lo puede en el justiniano, adoptar hijos o ser tutora de impúberes; está limitada, sobre la base de una *lex Voconia* del 169 a. C., en la capacidad de suceder; no puede, por disposición del senadoconsulto *Velleiano* del 46 d. C., contraer obligaciones en favor de otros (*intercedere*).

*

* *

Se ha dicho ya (p. 52) cómo se distingue de la capacidad jurídica la *capacidad de obrar*; y se ha dicho también que la distinción no puede ser transportada tal cual es al mundo romano. De cualquier manera, dado que el antiguo derecho romano consi-

²⁴ Ver un contrato del género en mis *Negotia*, nº 13.

deraba incapaces de derechos patrimoniales a las personas *alienae potestati subiectae*, el problema de la capacidad de obrar solamente se puede plantear para las personas *sui iuris* con relación a la edad (*infantes, impuberes, minores xxv annis*), al sexo (femenino), a las enfermedades mentales (*furiosi*), a las tendencias a la disipación (*prodigi*). A las distintas situaciones señaladas se vinculan aquellos poderes familiares o cargas obligatorias que se conceden bajo los nombres de *tutela* (*impuuberum*, comprendidos entre ellos los *infantes*, y *mulierum*) y de *curatela* (*furiosi, prodigi, minoris*), y que la mayoría de las veces funcionan como simple asistencia al acto realizado por el interesado. En épocas avanzadas, el desarrollo que lleva a atribuir cada vez mayor capacidad patrimonial a los hijos de familia, trasforma en limitaciones de la capacidad de obrar, la que era, en los orígenes, exclusión de la capacidad de derechos patrimoniales; así ocurre, en particular, por cuanto se refiere a los *bona adventicia*. Puntos a los que bastará haberse referido aquí, pero que deberán tratarse ampliamente al ocuparnos del derecho de familia.

§ 7. LAS PERSONAS JURÍDICAS

Se llama *persona jurídica* (y también *cuerpo* o *ente moral*) a todo ente diverso del hombre, a quien el ordenamiento jurídico reconozca la capacidad de derechos y de obligaciones.

La existencia de tales entes puede parecer, a primera vista, en contradicción con la máxima de que "*hominum causa omne ius constitutum est*". Pero esta máxima comprueba, simplemente, que el derecho sirve para alcanzar los fines que el hombre se propone en la vida social; fines que no son, sin embargo, necesariamente individuales, y tales que se puedan alcanzar en el ámbito de la actividad de un individuo. A los fines humanos es, a menudo, necesaria la actividad asociada de muchos hombres, no todos actualmente existentes o determinables, y que esta actividad se desarrolle por un tiempo más o menos largo, con frecuencia (frente a nuestra previsibilidad) infinito. Y es necesario, otras veces, que determinado patrimonio permanezca destinado a un fin de ventaja social, aun después de la vida de la persona física

que se propone este fin y de aquellas sobre cuya actividad ella puede directamente influir. Para proveer a tales exigencias se dispone, por el ordenamiento jurídico, de un aparato de normas tales que permitan lograr aquellos resultados prácticos que se alcanzarían si los varios hombres asociados fueran un hombre solo e inmortal, o si detrás del patrimonio destinado a un fin quedase siempre la persona del fundador. En definitiva, también aquí la norma exige siempre y solamente que determinados individuos (en general los que impropriamente se llaman representantes y más exactamente órganos de la persona jurídica) tengan este o aquel comportamiento; pero el procedimiento técnico de la personificación, mientras permite expresar en forma breve e incisiva disposiciones que de otra manera estarían dispersas en una larga serie de reglas, satisface al mismo tiempo la tendencia de nuestra mente a representarse bajo especie humana toda actividad espiritual, existente o imaginaria, que actúe en la persecución de un fin, toda disciplina que se imponga a nuestra conducta, todo poder que influya, positiva o negativamente, sobre nuestro bienestar²⁵.

²⁵ Decir, por ejemplo, que el hospital X es propietario del fundo Capenato, es un modo abreviado para decir que aquel fundo está destinado a asegurar en todo o en parte las rentas necesarias para el funcionamiento del hospital; que, por consiguiente, los extraños deben abstenerse de toda ingerencia en el fundo, como si el hospital fuese propietario; que los administradores del hospital deben administrarlo del mejor modo e invertir las rentas según el estatuto de la fundación. Decir que el municipio A debe cien mil a Ticio, es un modo abreviado de decir que sobre los fondos patrimoniales destinados a hacer frente a las necesidades colectivas de los habitantes del municipio, pesa un pasivo de cien mil, y que sobre tales fondos los administradores municipales deben satisfacer la deuda, del mismo modo en que habría estado obligado un deudor que administrase su hacienda individual.

En este sentido, considero que entre los dos puntos de vista que se disputan el campo en materia de personas jurídicas (el que las considera como ficciones del derecho objetivo, y el que las entiende como realidades por éste reconocidas), el más próximo a la verdad es el de la ficción: antes bien, creo que cuanto he dicho en el texto y brevemente ilustrado en esta nota no sea más que la expresión exacta de lo que piensan todos aquellos que ven en las personas jurídicas entes ficticios (en particular, creo ver también aquí un pensamiento afin al mío en PEROZZI, *Ist.*, I, p. 565). Quien afirma la realidad de la persona jurídica confunde, la mayoría de las veces, la realidad del fin (sobre el cual no podría haber discusión) y de sus medios materiales, con la del sujeto jurídico: es real el fin benéfico a que mira un hospital público, real el edificio a él destinado y sus accesorios, pero un deber jurídico y un derecho subjetivo no pueden considerarse propios del hospital sino por vía de abstracción.

Precisamente porque es resultado de un proceso de abstracción, la persona jurídica no ocupa su puesto en el sistema tan inmediata y necesariamente como la persona física, sino que es, más bien, el fruto de una evolución: sea en el sentido de que el primer reconocimiento está limitado a aquellas entre las personas jurídicas para las cuales se presenta más fácil la aproximación a la persona física, sea en el sentido de que la distinción entre la persona jurídica como tal y las personas físicas particulares que la integran o a través de las cuales se desarrolla su actividad, se opera por grados, y sólo en época avanzada se actúa perfectamente.

En la evolución del derecho romano, esto da lugar a dos fenómenos; el primero bien visible y, en consecuencia, ampliamente observado; el segundo tan tenue y delicado que sólo las más sutiles investigaciones recientes han podido darse cuenta de él. El primero es éste: que aun en el más notable florecimiento de la jurisprudencia clásica, el ordenamiento jurídico no supo personificar sino los entes resultantes de la agrupación de hombres, es decir, los pertenecientes a aquella categoría a que la doctrina civilística da el nombre de *corporaciones*, mientras que los otros tipos, y particularmente las *fundaciones*, solamente en el derecho justinianeo ofrecen algún primer reflejo de incertísima vida. El segundo es que el concepto mismo de corporación hubo de desarrollarse fatigosamente a través de la lucha con una concepción bastante más elemental y particularizante, según la cual los derechos y las obligaciones del grupo no eran todavía concebidos como propios del ente, sino como pertenecientes *pro parte*, aunque indivisibles en la totalidad, a cada uno de los componentes²⁶.

*
* *

Como se ha indicado, son corporaciones aquellas personas jurídicas que resultan de la agrupación (necesaria o voluntaria) de varios hombres, que se mantienen unidos por la comunidad de los fines a perseguir. Se ha dicho ya que este tipo de persona jurí-

²⁶ Para un delicadísimo análisis de los residuos de esta última concepción, cfr. MITTELS, *Römisches Privatrecht*, I, ps. 341 y ss. Ver también: SALEILLES, *De la personnalité juridique*, 1910, ps. 25 y ss.; RABEL, *Lineamenti*, ps. 426 y ss.

dica es el único conocido por los romanos; pero conviene agregar que ellos no adoptaron nunca una terminología ni desarrollaron un reglamento práctico que se refiriese a todas las que nosotros llamamos corporaciones, aunque sí han considerado y descrito los tipos particulares, como el *populus Romanus*, los *municipia* y las *coloniae*, los *collegia* y *sodalitates*²⁷. Lo que no impide que las reglas dictadas para cada uno de estos entes o categorías de entes coincidan en muchos puntos, y que aun la organización del *populus Romanus* haya servido de modelo a toda otra, aunque con las mutaciones necesarias a cada caso.

Populus Romanus (o, como a menudo se dice, *p. R. Quiritium*) es la denominación técnica del Estado considerado como persona; y expresa claramente la concepción, que los romanos mismos tuvieron, de una agrupación de personas físicas²⁸. Su característica es la soberanía, que lo distingue no sólo del particular, sino también —como los juristas lo señalan— de las comunidades subordinadas, que “*privatorum loco habentur*” (D. 50, 16, 16). La calificación de ente soberano es para los romanos tan absorbente como para no poder concebir que el pueblo entre en relaciones de derecho privado en condiciones de paridad con personas físicas (cfr. p. 33); por lo tanto, sea el Estado deudor o acreedor, vendedor o locador de inmuebles, propietario o heredero o legatario, la relación de que él es parte no es nunca identificada con las relaciones del mismo nombre que existen entre los ciudadanos, y no da jamás lugar a un proceso ordinario en el cual el Estado sea actor o demandado, sino a recursos de carácter administrativo. El Estado romano tiene naturalmente, como toda persona jurídica, su patrimonio, del todo independiente del de los individuos; es a él que se da el nombre de *aerarium populi Romani*.

La posición de las numerosas *civitates* que forman parte del Imperio tiene también sus presupuestos en el derecho público,

²⁷ Solamente en el lenguaje justiniano la palabra *universitas*, ya usada por GAYO como nombre común de los *municipios* y de las *coloniae*, sirve a menudo para indicar todas aquellas que nosotros llamaremos corporaciones, con excepción del *populus Romanus*. Cfr. H. KRUEGER, en “Rev. Fundac. Savigny”, 29, 1908, ps. 519 y ss.; ALBERTARIO, en “Annali della Fac. di Giur. Univ. Perugia”, 4ª serie, 1, 1919, ps. 28 y ss., ahora en los *Studi cit.*, I, ps. 97 y ss.

²⁸ La expresión *res publica* (= *res populi*) es un derivado, e indica preferentemente el conjunto de los fines para los cuales se organiza el pueblo.

pero esto no impide que sea en parte regulada por las normas del derecho privado²⁹.

Corresponde, sin embargo, distinguir para la época anterior al 212 d. C., entre las ciudades que permanecieron extranjeras y las incorporadas a la ciudadanía romana (*municipia*). Personas jurídicas corporativas son unas y otras, pero las primeras son formalmente soberanas y las segundas no; de manera que mientras las primeras se hallan, frente a sus ciudadanos, en situación análoga a la del Estado romano, en las segundas encuentra más amplia aplicación la máxima "*privatorum loco habentur*"; y hasta la *constitutio Antoniniana* del 212 solamente a las segundas se les aplica el derecho romano. Parece, en cambio, que para la época republicana debe negarse la personalidad de las *coloniae civium Romanorum*, simples prolongaciones (*filiales*, según la expresión de MITTEIS) de la comunidad romana; pero en la época imperial toda diferencia entre municipios y colonias desaparece. Desde el punto de vista del derecho privado, la comunidad puede ser sujeto de cualquier relación patrimonial, y también de algunas relaciones personales como la tutela y el patronato; mas la neta separación entre las relaciones de la persona jurídica y la de los individuos parece haber sido afirmada por los juristas precisamente con relación a las *civitates*³⁰. En consecuencia, éstas pueden también ser partes en los negocios jurídicos generadores de derechos y obligaciones de que son capaces, especialmente en los contratos y en los actos constitutivos de derechos reales. Pareció a los clásicos que la imposibilidad de realizar el acto de aceptación las hiciese incapaces de ser instituídas herederas; se admitió, sin embargo, después de algunas dudas, que fuesen beneficiarias de legados, y quizá también de fideicomisos universales; y una constitución del emperador León (C. 6, 24, 12, año 469) admitió finalmente la institución de heredero en su favor. Frente a los particulares con los cuales están en relación de negocio, la posición de las *civitates* es ambigua; mientras a veces, sobre todo en las ven-

²⁹ La máxima de GAYO (D. 50, 16, 16) "*civitates privatorum loco habentur*" no quiere ya negar a las ciudades el carácter de entes públicos, sino solamente afirmar que a diferencia de la *civitas* romana, pueden ser parte de relaciones de derecho privado a la par de los individuos.

³⁰ D. 3, 4, 7, § 1: "*Sí quid universitati debetur, singulis non debetur: nec quod debet universitas singuli debent*".

tas y locaciones, la comunidad se presenta como soberana, con la consiguiente exclusión del proceso civil; mientras a veces también las disputas en torno a la propiedad comunal de los terrenos se desarrollan en forma administrativa, la mayor parte de las veces, en cambio (y especialmente en materia de mutuos, de estipulaciones, de legados), particular y ente público están sujetos al derecho y al proceso privado sobre un pie de perfecta igualdad: tanto es así que en el Edicto del pretor, cláusulas especiales regulaban la representación de las ciudades en juicio³¹.

En los negocios jurídicos, los órganos de la comunidad no son normalmente los mismos a través de los cuales se desarrollan las relaciones del derecho público (por lo común, magistrados y consejos llamados *curiae*); como sujeto de derecho privado, la *civitas* está representada por especiales *actores*, con poderes estrictamente delimitados, o por sus esclavos (de conformidad con el principio de que todo esclavo puede adquirir para el patrón), en el derecho más avanzado también por *curatores* y *syndici* permanentes.

Personas jurídicas menores, dentro del ámbito del Estado y de la ciudad, son los *collegia* y las *sodalitates*. En el sentido más riguroso, el nombre de *collegium* corresponde a agrupaciones formadas con fines de culto³²: fines religiosos debieron tener no solamente aquellas que también en época avanzada muestran en forma evidente esta estructura (*collegia cultorum*), sino también aquellas organizaciones de oficios que la tradición hace remontar hasta Numa Pompilio, y los más recientes *collegia tenuiorum*, o *funeraticia*, grupos de personas humildes que se reúnen con el fin de asegurarse una sepultura. Alguna tendencia religiosa hay también en las *sodalitates*, que se reúnen en banquetes comunes. Según declaraciones de juristas clásicos, *collegia* y *sodalitates* eran

³¹ Cfr. en la reconstrucción de LENEL (*Das Edictum perpetuum*, 3ª ed., 1927) los §§ 31 (*quibus municipium nomine agere liceat*) y 33 (*quod adversus municipes agatur*).

³² Se destaca, sin embargo, que no siempre el nombre de *collegium* indica una persona jurídica. Los más antiguos parecen haber sido los cuatro grandes colegios sacerdotales (*pontificum*, *augurum*, *vii virum epulonum*, *xv virum sacris faciundis*), que son oficios estatales (cfr. MIRREIS, loc. cit., ps. 391, n. 5, y 393, n. 9) y de cuya calidad de personas jurídicas se puede dudar. Tal duda es todavía más justificada para los *collegia magistratum* (*consulum*, *tribunorum plebis*, etc.).

ya conocidos por las XII Tablas, que habrían consentido explícitamente que se dieran estatutos propios, aunque no conteniendo normas en contraste con el derecho de la Ciudad (*dum ne quid ex publica lege corrumpant*). Pero en los periodos turbios de la última época republicana el Estado se tornó más severo, sobre todo por haberse transformado la mayor parte de los colegios y sodalicios, de comunidades religiosas en sectas políticas más o menos secretas. De aquí la frecuencia de la disolución autoritaria de todos los colegios que hacían oposición al partido *pro tempore* dominante. Una ley votada por los comicios a propuesta de Augusto, la *lex Iulia de collegiis* (año 7 a. C.?) los disolvió nuevamente, exceptuando aquellos de más antigua y noble tradición, y sometió a la autorización del Senado toda constitución de nuevos colegios: la ley se refería sólo a Roma, pero sus disposiciones fueron extendidas por senadoconsulto al resto de Italia, por mandatos imperiales a las provincias. Sin embargo, muchas autorizaciones (por ejemplo, a los *collegia funeraticia*) fueron otorgadas en bloque mediante senadoconsultos; y más tarde el imperio cristiano amplió considerablemente el número de las corporaciones lícitas, comprendiendo en ellas sea a las iglesias particulares y monasterios, sea a la Iglesia Católica en su unidad.

Es problema muy discutido entre los romanistas si la autorización conferida por el Estado servía para atribuir únicamente la autonomía patrimonial a una asociación ya lícita como tal, o si faltaba a los romanos el concepto de la asociación lícita y no personificada. Parece ser que la disputa, totalmente apoyada sobre la interpretación del pasaje de GAYO, en D. 3, 4, 1 pr., § 1, debe resolverse en el segundo sentido: la voluntad de cierto número de personas (por lo menos tres) de constituir un colegio, encuentra su forma jurídica en la creación de una caja común (*arca communis*) y su declaración explícita en la solicitud de autorización; la decisión de la autoridad sobre tal solicitud representa el pleno reconocimiento de la corporación, con la autonomía patrimonial que los componentes han demostrado querer, o el desconocimiento, que excluye, desde luego, la lícitud de la asociación.

Por la amplitud de la capacidad jurídica, el régimen de los *collegia* y *sodalitates* se inspira en el de las *civitates*: mientras pronto se reconoció su capacidad para los actos patrimoniales en-

tre vivos, la admisión de la capacidad de manumitir esclavos y de recibir legados dió lugar a dificultades que solamente en la época de los Antoninos fueron definitivamente superadas: la capacidad para ser instituídas herederas es también aquí un aporte de la época posclásica. Corresponde observar, de todos modos, que nuestras noticias no llegan más allá del derecho clásico; que en la época más antigua se acostumbrara considerar al patrimonio de la corporación como perteneciente *pro parte* a los miembros, parece sugerido no sólo por la dirección general del desarrollo (cfr. *supra*, p. 77), sino también por el hecho de que la más antigua forma de procedimiento, la de las *legis actiones*, no conoce medios técnicos para llevar a la práctica la representación de las corporaciones. Tal representación fué, en cambio, regulada por el derecho pretorio: los *actores* que éste contempla, en lo relativo al proceso, son órganos de los *collegia* y de las *sodalitates*, también en los actos de derecho material.

El problema de la extinción, que no es objeto de regulación respecto a las *civitates* (éstas se consideran inmortales, y su eventual extinción es motivo de providencias especiales), se plantea, en cambio, a propósito de las corporaciones privadas; las cuales se extinguen, sea cuando desaparecen todos los miembros (no basta que se reduzcan a menos de tres, ya que el único supérstite puede encontrar el modo de integrar el número mínimo de los componentes), sea cuando haya sido alcanzado el fin propuesto, sea por disolución por orden de la autoridad pública. El destino del patrimonio en las dos últimas hipótesis es la más característica supervivencia de la concepción primitiva del condominio: se divide, en efecto, entre los miembros.

Un tipo muy controvertido de personas jurídicas corporativas, distintas de las otras por la limitación de su capacidad sólo a la esfera de los negocios conexos con su función económica, se da, según parece, en las sociedades entre adjudicatarios de los impuestos, obras y monopolios públicos (*societates publicanorum*, que se distinguen en *s. vectigalium publicorum*, *salinarum*, *aurifodinarum*, *argentifodinarum*, etc.). La estructura de estas *societates* es, sin embargo, controvertida; y sobre todo se discute si la capacidad jurídica era reconocida a sociedades formadas a veces entre el empresario de una adjudicación (*manceps*) y otros que se le

agregasen, o a corporaciones en las que se reuniesen varios especuladores que dedicaban su actividad a uno u otro tipo de adjudicaciones³³.

*
* *
*

Se ha dicho ya que es desconocida para los romanos la fundación, es decir, la personificación del patrimonio destinado a un fin. Lo que no quiere decir que ellos no hayan sentido jamás la necesidad de destinar perpetuamente la renta de determinados fondos a la persecución de ciertos fines, y preferentemente a festejos públicos y a beneficencia: bastarían las numerosas instituciones alimentarias de la edad imperial para demostrar lo contrario. Pero les faltaba aquella potente facultad de abstracción necesaria para suponer que el patrimonio sea titular de sí mismo, en la persecución del fin impuesto por el fundador; por eso debieron servirse de medios indirectos, y en particular de donaciones y de legados sujetos a la carga (*modus*) de las erogaciones queridas, y dispuestos, la mayoría de las veces, en favor de municipios, cuya duración indefinida garantizaba que la carga sería cumplida por larguísimo tiempo. Plinio el Joven, por ejemplo, queriendo beneficiar a los pobres de Como, su ciudad, transmitió al municipio la propiedad de ciertos fundos, a condición de que los concediese a particulares según el régimen de los *agri vectigales* (cfr. cap. ix), y destinase el canon a beneficio de los pobres.

En el imperio cristiano, la promoción, tutela y coordinación de todas las iniciativas benéficas figura entre las tareas propias de la Iglesia. Bajo el nombre de *piae causae*, JUSTINIANO comprende todos los fines religiosos y de beneficencia a los cuales una donación o un legado pueden ser destinados (construcción y financiación de casas de expósitos, nosocomios, asilos; rescate de prisioneros de guerra, etc.); y protege las disposiciones destinadas a fines semejantes con varios privilegios, en particular exceptuándolos de las formalidades prescritas para las donaciones. Este tratamiento común unificaba en cierto modo todas las erogacio-

³³ Para las distintas doctrinas, cfr. especialmente COHN, *Zum römischen Vereinsrecht* [Sobre el derecho romano de asociación], ps. 155 y ss.; KNIFF, *Societas publicanorum*, I, 1896; y por último MITTEIS, *Römisches Privatrecht*, I, ps. 493 y ss. El tema es de aquellos que exigen una revisión cuidadosa.

nes pías, cualquiera fuese su estructura jurídica; y por eso ha dado origen a la difundida opinión de que el derecho justiniano ha personificado finalmente a las fundaciones. Pero no parece que esto pueda afirmarse; aparte de que muchas veces los disponentes mismos designaban como encargados de la ejecución a la Iglesia o al obispo, las constituciones establecen —para el caso de que haya sido determinado el fin y no los medios— que la Iglesia o el obispo deban igualmente cuidar de la ejecución; las expresiones usadas a este respecto muestran indudablemente —de conformidad con el espíritu del derecho justiniano— cierta indiferencia por la forma jurídica, una decidida tendencia a llevar a la práctica, de cualquier modo, la voluntad benéfica del disponente; pero no llegan nunca a afirmar precisamente la personificación del patrimonio destinado al fin, y mucho menos a dar a las palabras *piae causae* este significado específico⁸⁴.

Mucho más decididamente es reconocida, pero sólo por el derecho justiniano, la personalidad de la *herencia yacente*, es decir, del patrimonio hereditario que queda privado de titular hasta que el heredero llamado a recogerlo haya manifestado la voluntad de aceptar. La antigua concepción romana, que consideraba este patrimonio como privado de sujeto (*res nullius*), no podía impedir que se sintiese la necesidad de encontrar rápidamente a quién atribuir los incrementos y disminuciones que sufría (nacimiento o muerte de esclavos o de animales, herencias y legados que los esclavos hereditarios adquirían, créditos de ellos mismos, etc.). La jurisprudencia aplicó, al principio, el criterio de que, dada la retroactividad de la aceptación, toda ventaja o desventaja está reservada al heredero (así, en su redacción originaria, D. 9, 2, 13 § 2); posteriormente, pareciendo quizá demasiado audaz considerar como parte de relaciones jurídicas actuales a una persona entonces incierta, se prefirió la ficción de que la vida del causante se prolongase hasta el momento de la aceptación, y se dijo que la herencia yacente "*personae defuncti vicem sustinet*", "*defuncti locum optinet*", o se emplearon otras expresiones semejantes. En muchas partes del Digesto encontramos, en cambio, a la herencia misma considerada como *persona*, o —lo que es lo mismo— como

⁸⁴ Cfr.: CUGIA, *Il termine "piae causae"*, en los *Studi in onore di C. Fadda*, v, ps. 227 y ss.; SALEILLES, *Les piae causae dans le droit de Justinien*, en *Mélanges Gérardin*, 1907, ps. 513 y ss.

domina de las cosas hereditarias; pero parece ya demostrado que aquellos pasajes están interpolados, y que la teoría en ellos afirmada es sencillamente posclásica³⁵.

Corresponderá, en fin, señalar al fisco, que también se acostumbra a incluir entre las personas jurídicas. No es, por cierto, ésta su estructura originaria; más aún, al comienzo del principado el nombre de fisco fué atribuido al patrimonio de la administración imperial, como distinto del verdadero patrimonio de la ciudad, *aerarium populi Romani*. Pero a continuación, por efecto del cada vez mayor predominio del príncipe sobre los órganos de la república, el fisco absorbe al erario y, por el contrario, se separa de los bienes personales del emperador, asumiendo la estructura de caja general del Estado. En este punto, en el lenguaje de la jurisprudencia y de las constituciones, el fisco parece considerado como un ente por sí mismo, y ya no es puesto en relación ni con el *populus* ni con el emperador; se habla de *ius fisci*, de *debitores fisci*, de *stationes fisci*. Es, sin embargo, muy discutible que esta terminología deba considerarse como la expresión de una verdadera personificación; quizá no haya que excluir que tenga un valor meramente aproximativo y de comodidad, y que por lo tanto el fisco imperial, aun en el pensamiento jurídico del tiempo, no sea más que el patrimonio del Estado, tal como lo había sido el *aerarium* republicano.

³⁵ Cfr.: DI MARZO, *Studi in onore di V. Scialoja*, II, ps. 53 y ss.; RABEL, *Lineamenti*, p. 533 y n. 3. La crítica más eficaz de la personificación de la herencia yacente es de V. SCIALOJA (*Corso di istituzioni di dir. rom.*, 1911, ps. 316 y ss.), quien parangona la herencia yacente con aquel molde que la adhesión de la lava volcánica a los cuerpos humanos de Pompeya, había dejado después de la combustión de los cadáveres, de manera que haciendo penetrar yeso en él se habían reobtenido las figuras (desgraciadamente destruidas en la última guerra). Es, en suma, el derecho objetivo el que, en vista del futuro advenimiento del heredero, quiere que se tengan por firmes todas las relaciones, como si existiese la persona de su titular. Pero quizá la elegantísima comparación es aplicable también fuera de la hipótesis de la herencia yacente: ¿no es ésta, en el fondo, la función del ordenamiento jurídico en todo caso de personificación? El establecer si en las distintas hipótesis convenga o no recurrir a la personificación, es problema de *economía jurídica*; y es buena tendencia de la doctrina (como lo señala el mismo SCIALOJA) recurrir a ella solamente cuando sea particularmente compleja la red de relaciones jurídicas dispuestas en torno al interés no individualizado.

FRANJA MORADA

CAPÍTULO III

EL NEGOCIO JURÍDICO

§ 1. DEFINICIONES Y CLASIFICACIONES FUNDAMENTALES. LAS FORMAS DE LAS MANIFESTACIONES DE VOLUNTAD

Se ha dicho ya (p. 26) que la jurisprudencia romana no elaboró una doctrina general del negocio jurídico. Sin embargo, no podían faltar doctrinas particulares que fueran susceptibles de una aplicación más o menos uniforme a todos los actos jurídicos o, por lo menos, a vastos grupos de ellos; tales las doctrinas de la *condicio* y del *dies*, de la representación, del dolo, de la violencia. En consecuencia, es indispensable también en este campo una integración del pensamiento romano con el de la doctrina posterior, bizantina, medieval y moderna; estas distintas corrientes de pensamiento son, por lo demás, con relación al tema de que nos ocupamos, tan confusas y mezcladas entre sí que hacen bastante fatigosa la tarea que nos proponemos de mantener separado de las superestructuras posteriores lo que es verdaderamente romano¹.

Remitiéndonos al concepto ya formulado al principio (p. 23), podemos definir el negocio jurídico como la manifestación individual de voluntad, o la resultante de varias manifestaciones individuales, dirigida hacia la obtención de fines prácticos y provista por el derecho objetivo de efectos lo más conformes posible con aquellos fines, mediante la creación de nuevas relaciones jurídicas o la modificación o extinción de relaciones jurídicas existentes.

¹ El análisis dedicado al negocio jurídico es el objeto principal del magnífico volumen de BETTI, *Diritto romano*, I, Padova, 1935; donde está por cierto, superpuesta a las ideas romanas, toda una problemática que no era la de los *prudentes*, pero siempre con referencias precisas a los esquemas propios del mundo clásico.

Debe destacarse particularmente un punto.

La coincidencia que a primera vista se advierte entre los fines perseguidos por las partes y los efectos del negocio, no debe llevarnos necesariamente a identificarlos. El individuo que participa en un negocio jurídico tiene como mira ciertos intereses que trata de satisfacer: adquirir la disponibilidad de un fundo, habitar una casa, hacer que sus bienes lleguen —después de su muerte— a poder de determinadas personas, etc.; los medios con que el derecho objetivo le permitirá alcanzar estos resultados no los conoce, o sólo tiene de ellos un conocimiento aproximado. Por lo demás, la posición del ordenamiento jurídico frente a las manifestaciones de voluntad, no es siempre, como veremos, igualmente respetuosa de los fines que las partes se propusieron; la evolución se desarrolla en el sentido de adecuar cada vez mejor a estos últimos los efectos jurídicos de aquéllas.

Al hablar de manifestaciones de voluntad, o de resultantes de varias manifestaciones, se ha anticipado la distinción (no romana, sino doctrinal) entre los negocios jurídicos *unilaterales* y *bilaterales*. A esta segunda categoría pertenece la gran mayoría de los negocios, en particular los contratos, los actos de transmisión de la propiedad y de constitución de derechos reales, la adopción; en cambio, son *unilaterales* (si no en la estructura formal romana, por lo menos en la valoración que la jurisprudencia hace de su fundamento práctico) el testamento y la emancipación².

² A veces, para quien considera la cuestión en el terreno de la pura teoría, la distinción parece desaparecer: puede, por ejemplo, considerarse que lo mismo que la donación se hace perfecta sólo cuando la acepta el donatario, también el testamento adquiere eficacia sólo cuando el heredero llamado acepta; y deducir que, por consiguiente, también el testamento es un negocio bilateral, y precisamente un contrato. La objeción que desde un punto de vista puramente técnico puede oponerse (esto es, que no es posible el encuentro de dos voluntades cuando una de ellas ha desaparecido con el sujeto que la expresó), podría quizá ser superada; mayor importancia tiene la observación de que, en la conciencia jurídica romana como en la nuestra, el testamento es una declaración autoritativa y tiene, como la ley, su propio vigor, independientemente de la adhesión que se le preste o niegue.

En otro sentido se ha hecho en el texto una reserva sobre la unilateralidad del testamento y de la emancipación: siendo el primero una de las aplicaciones de la *mancipatio*, la segunda un tejido complicado de *mancipationes* y de *in iure cessiones*, era necesaria la colaboración de varias per-

La ciencia distingue también entre negocios *mortis causa* e *inter vivos*: los primeros están destinados a dar normas para después de la muerte del disponente o, si bilaterales, de una de las partes; mientras los segundos producen normalmente sus efectos en vida de ambas. El punto de partida de la distinción, está en el hecho de encontrarse en las fuentes romanas la expresión *mortis causa*; pero allí, esta expresión está usada solamente en relación con ciertos modos excepcionales de disposición y de adquisición (*mortis causa donatio*, *mortis causa capio*), y nunca con relación a las disposiciones testamentarias fundamentales, como la institución de herederos y el legado³.

*
* *

Acerca de las formas de la manifestación de voluntad, el ordenamiento jurídico puede adoptar diversos puntos de vista: puede exigir, para reconocer efectos jurídicos a la voluntad privada, que ésta sea expresada en modos rígidamente determinados; puede limitarse a imponer que la manifestación sea cumplida con cierto medio de comunicación (por ejemplo, por escrito); puede, en fin, reconocer aquellos efectos a la voluntad manifestada de cualquier manera. Los negocios de la primera y de la segunda especies se llaman *solemnes*; los de la tercera especie, *no solemnes*.

Pero cuando se trata de casos de la primera especie, es decir, cuando las partes en el negocio jurídico deben limitarse a repetir frases preestablecidas o a llenar los moldes de determinados módulos, al *formalismo externo*, consistente en no reconocer eficacia a la voluntad privada si no se la expresa en aquellas formas determinadas, corresponde, por lo menos en los orígenes, también un formalismo *interno* en el sentido de que, cuando aquellas frases hayan sido repetidas o aquellos módulos satisfechos, no se practica investigación alguna sobre la intención de las partes que las han cumplido; es más, corresponda o no la voluntad real de

sonas, y que éstas tuvieran la apariencia de declarar su voluntad. Pero eran, en realidad, simples figurantes, que por amistad o mediante una pequeña compensación hacían los gestos y pronunciaban las palabras que correspondían, en interés del testador o del emancipante.

³ Cfr. CUGIA, *L'espressione "mortis causa"*, Napoli, 1910.

las partes a las palabras de la fórmula, el efecto jurídico se produce igualmente⁴. En cambio, cuando el ordenamiento jurídico no prescribe una forma, o cuando la forma está prescrita sólo como una especie de vestimenta con que la sustancia preelegida por las partes debe cubrirse, entonces las palabras de la manifestación no son más que los signos a través de los cuales se busca la voluntad expresada; también sobre esta investigación influyen los distintos climas jurídicos, y por lo común los ambientes en que el formalismo predomina, permanecen un tanto vinculados a la letra, aun para los negocios que consideran más libres; pero, de todos modos, la intención fundamental que condujo a las partes al negocio jurídico, la *causa* del negocio mismo (cfr. p. 332), tiene importancia decisiva.

De ahí la distinción entre negocios *formales* y *causales*; los primeros son aquellos en que la manifestación vale por sí misma, y la exigencia de una intención de las partes sólo es sentida en cuanto su ausencia absoluta hace nulo el negocio; los segundos son aquellos en que la manifestación es simple medio para establecer la intención de las partes, que es la *causa* de los negocios mismos⁵.

Lo que hemos venido diciendo resultará más claro luego de un examen de los más típicos negocios jurídicos del derecho romano. En el derecho antiquísimo, totalmente dominado por el formalismo externo e interno y por aquel criterio que IHERING llamó de economía de los medios jurídicos, casi todos los negocios se pueden reducir a los tres tipos de la *mancipatio*, de la *in iure cessio*, de la *stipulatio*. La primera (cap. VII, § 2, n° 10), que es originariamente un cambio inmediato de cosa contra precio, se transforma con el trascurso del tiempo en negocio formal de transferencia de la propiedad, y, con modificaciones tal vez bastante leves, es adaptada a la constitución de las servidumbres rústicas, a la garantía de las obligaciones (*fiducia*, *nexum*), a la disolución del

⁴ Para la atenuación que el principio recibe ya en la época clásica, cuando la falta absoluta de la intención práctica correspondiente a la forma empleada produce la nulidad del negocio, cfr. espec. BETTI, *Dir. rom.*, I, ps. 235 y ss.

⁵ Sobre los criterios con arreglo a los cuales puede conducirse tal investigación, y sobre el diverso punto de vista del derecho clásico y del justiniano, cfr. p. 110.

vínculo obligatorio (*solutio per aes et libram*), a las disposiciones de última voluntad (*mancipatio familiæ*), a la adquisición de la potestad sobre la mujer y la nuera (*coemptio*), a la renuncia a la patria potestad (*emancipatio*). La segunda (cap. VII, § 2, n° 9), que es un proceso ficticio, sirve para transmitir a otros la propiedad, para constituir el usufructo y toda especie de servidumbre, para transmitir a otros la posición de heredero o de tutor, para manumitir los esclavos (*manumissio vindicta*). La tercera (cap. XIV, § 3, n° 5) es un contrato obligatorio abstracto, que se perfecciona con una pregunta del futuro acreedor y con una respuesta concordante del deudor; en ella se puede volcar cualquier contenido obligatorio, pero sin indicación de la causa por la que se asume la obligación. Es inútil decir cómo en estos negocios la voluntad de las partes está constreñida por las palabras y por los gestos prescritos: la indiferencia del ordenamiento jurídico por la intención no exactamente traducida en las palabras pronunciadas, está expresada con particular energía en un versículo de las XII Tablas referente a la *mancipatio*: *uti lingua nuncupassit, ita ius esto*.

La red de los negocios jurídicos formales se rompe, aparte de algún negocio de menor importancia, solamente en el siglo III a. C., con el reconocimiento de los cuatro contratos del *ius gentium* (cfr. ps. 30 y ss.): abierto así el camino, también el derecho pretorio fué otorgando protección a otras convenciones libres, como el depósito, el comodato, la prenda.

Entre las dos categorías de los negocios más rígidamente solemnes y formales y de los no solemnes y causales, falta en el derecho antiguo aquella categoría intermedia, en la cual la forma está impuesta sólo como un revestimiento exterior. También en el testamento, donde la venta ficticia del patrimonio a un extraño se transforma bien pronto en un accesorio (y por derecho pretorio puede ser sustituida por los sellos de los siete testigos), el formalismo se vuelve sobre las disposiciones particulares, como la institución de herederos, los legados y las manumisiones de esclavos. Sin embargo, ya en la época clásica estos formularios oponen menor resistencia, en cuanto se deja al testador la facultad de elegir entre diversos módulos o se admite que disposiciones no válidas con relación al tipo por él elegido, valgan como si hubiesen sido cumplidas según otro tipo que consintiera su validez;

además, la admisión del fideicomiso y del codicilo, sustitutivos no solemnes de las disposiciones testamentarias particulares y del testamento en su conjunto, ofrecen el más vasto campo a la libre expresión de la voluntad de los testadores (*voluntas testantium*), cuya investigación se convierte en uno de los motivos dominantes de la jurisprudencia. El testamento se encamina así a convertirse, tal cual es en nuestro derecho, en un negocio solemne pero causal.

Pero el terreno más fértil para tales negocios es el derecho posclásico y justiniano. Desaparecidas la *mancipatio* y la *in iure cessio* en sus innumerables aplicaciones, reducida la *stipulatio* a una cláusula escrita confirmatoria de un contrato cuyas disposiciones están redactadas en los términos más libres, las formas que para los distintos actos se requieren son todas exteriores: documento escrito, acto notarial, insinuación en los *gesta* de los magistrados, son medios de *comunicación* de la voluntad que dejan amplio campo a la *expresión* de la voluntad misma.

Respecto a los negocios no solemnes, se suele distinguir entre manifestación de voluntad *expresa* y *tácita*, o —más exactamente— *explícita* e *implícita*. Es explícita la manifestación que resulta de palabras o de gestos destinados a actuarla: así, yo habré consentido explícitamente en un contrato de compraventa, sea que haya pronunciado o escrito palabras de aceptación, sea que las haya hecho pronunciar por una persona a quien encargara de ello (*nuncius*), sea que haya hecho un signo de asentimiento. En cambio, es implícita la manifestación que resulta de palabras o de gestos no destinados a ese fin, pero tales que de ellos deba necesariamente inducirse, según la costumbre social, una voluntad dirigida hacia determinado negocio; así, el hecho de pagar la cosa que se nos ofrece en venta, el de iniciar los actos de ejecución del encargo (mandato) que otro nos da, el de tomar un diario del quiosco de un vendedor. El derecho romano, que en los contratos consensuales admite manifestaciones explícitas e implícitas, considera otras veces la manifestación implícita como un negocio jurídico en sí, distinto pero de efectos iguales a los de otro negocio, solemne, dispuesto al mismo fin: así, la *pro herede gestio*, que consiste en comportarse en una ocasión cualquiera como heredero, equivale a la aceptación de la herencia, del mismo modo que el acto solemne (*cretio*) realizado expresamente para manifestar la voluntad de aceptar.

§ 2. LOS ELEMENTOS DEL NEGOCIO JURÍDICO. CONDICIÓN, TÉRMINO, MODO.

Tomando como base de la definición del negocio jurídico la manifestación de voluntad, hemos considerado a esta última como algo simple e indivisible. Corresponde, sin embargo, formular al respecto varias observaciones.

La primera es ésta: que la terminología científica es muy oscilante en los casos en que un acto reúne conjuntamente muchas manifestaciones de voluntad; caso típico es el testamento, comprensivo de instituciones de herederos, de legados, de nombramientos de tutores, de manumisiones de esclavos, etc., disposiciones cuya suerte puede ser jurídicamente separada y diferente. La doctrina llama con mucha frecuencia negocio jurídico al acto en que las distintas manifestaciones de voluntad se reúnen, pero luego se ve obligada a aplicar las reglas del negocio jurídico también a las disposiciones particulares. Esto es quizá inevitable, y no da lugar a graves dificultades con tal de que, caso por caso, se entienda sobre la referencia de las distintas reglas de derecho y cláusulas del negocio al todo o a las partes.

La segunda, mucho más notable, es que, aun cuando la manifestación de voluntad es verdaderamente indivisible, en el sentido de que no se le podría dar una actuación parcial, pueden, sin embargo, distinguirse en ella varios *elementos*, cada uno de los cuales, aunque no querido por las partes sino conjuntamente con los otros y en función de ellos puede, no obstante, ser conceptualmente aislado. Supongamos que yo venda mi casa por cien mil sestercios a pagar hasta el 30 de junio, y que preste garantía contra la reivindicación que un tercero pueda intentar contra el comprador (evicción); en esas manifestaciones de voluntad del comprador y mía, pueden distinguirse los siguientes elementos: a) paso de la casa al goce pacífico de aquél; b) transferencia de la propiedad de los cien mil sestercios de él a mí; c) garantía contra la evicción; d) tiempo en el que deberá realizarse el pago del precio.

Ahora bien: si se los analiza detenidamente, se observa que estos elementos tienen, con relación al contrato tipo de compraventa tal como es regulado por el derecho romano, diverso valor.

Los elementos a y b son tales que sin ellos no se tendría una compraventa: contrato en el cual, por definición, una de las partes se obliga a procurar a la otra el goce pacífico de una cosa, mediante la contraprestación de un precio. El elemento c es, en cambio, simplemente una consecuencia normal del contrato; tanto es así que mi obligación de garantía subsistiría aunque nada se hubiere dicho al respecto; sin embargo, habríamos podido ponernos de acuerdo en el sentido de reducir notablemente esta obligación (*pactum de non praestanda evictione*). El elemento d, en fin, deriva exclusivamente del arbitrio de las partes: si nada hubiésemos pactado sobre el particular, yo podría pretender el precio inmediatamente.

Por eso la doctrina suele distinguir los elementos del negocio jurídico en tres categorías: *essentialia negotii*, sin los cuales no se produce ningún efecto jurídico, o, por lo menos, no se producen los efectos correspondientes al tipo de negocio que las partes tenían en mira⁶; *naturalia negotii*, elementos que el ordenamiento jurídico establece como normales, pero dejando a las partes la libertad de disponer diversamente⁷; *accidentalia negotii*, es decir, disposiciones tomadas por las partes dentro de los límites impuestos a su libertad de disponer.

Es claro que ni los *essentialia* ni los *naturalia negotii* podrían examinarse en este lugar: ellos son fijados por el ordenamiento jurídico con relación a cada negocio en particular (o, eventualmente, con relación a grupos más o menos amplios), y, en consecuencia, su examen no puede tener lugar sino cuando se trate de cada uno de ellos en especial. Los *accidentalia*, en cambio,

⁶ Si corresponde una u otra solución, no puede decidirse sino caso por caso, teniendo en cuenta los principios generales del sistema jurídico de que se trata. En materia de contratos, por ejemplo, nuestro derecho vigente, que se inspira en el principio de la libertad contractual, puede fácilmente admitir que al contrato típico que las partes tuvieron en mira, y del cual no concurren los extremos, se sustituya un contrato no típico (innominado) conforme a la intención por ellas manifestada: la única cuestión a examinar consistiría en la concurrencia o no de los requisitos generales de los contratos. Para el derecho romano, en cambio, que sólo conoce contratos típicos, habría que excluir casi siempre semejante *conversión*: los mismos contratos innominados (sobre los cuales cfr. cap. xiv, § 2, n° 6) sólo son reconocidos como tales por el derecho justinianeo, y sometidos también en esta época a requisitos bastante restrictivos.

⁷ Como se ve, la distinción entre *essentialia* y *naturalia negotii* es el reflejo de la que ya hemos visto (p. 34) entre normas imperativas (*ius publicum* en el sentido más amplio) y dispositivas.

mientras en su mayor parte entran en aquella esfera de libre disposición de las partes que el derecho no limita preventivamente con sus normas (así, la determinación del *monto* del precio en la venta o del alquiler en la locación, la de las provisiones que se venden con el fundo o que quedan para el vendedor, etc.), pueden en alguna parte referirse a ciertos tipos fundamentales, susceptibles de encontrarse en negocios de las especies más diversas. Estos tipos, de los cuales basta solamente que nos ocupemos aquí, son la condición, el término y el modo.

*
* *

Se llama condición (*condicio*) a una cláusula del negocio jurídico en virtud de la cual la eficacia de éste o la cesación de tal eficacia depende de la verificación de un acontecimiento futuro e incierto; menos rigurosamente, pero por una trasposición fácilmente explicable, se llama condición también al acontecimiento de cuya verificación dependen los efectos del negocio o su cesación. Según que la condición se refiera a la iniciación de los efectos o a su cesación, la llamamos *suspensiva* o *resolutoria*: es suspensiva la condición impuesta a mi promesa de dar cien, si digo que los daré si gano en la lotería; es resolutoria la condición que se impone al contrato de compraventa, estableciendo que la venta se tendrá por no realizada si dentro de cierto tiempo el vendedor recibe una oferta mejor (*in diem addictio*). Pero la distinción es moderna. Necesidades análogas a aquellas con que se provee con nuestra condición resolutoria las sentían también los romanos, pero su técnica jurídica no conoció más que la condición suspensiva, y en consecuencia se vió constreñida a elegir entre esta alternativa: o transformar la condición resolutoria en la suspensión opuesta, o admitir que al negocio jurídico principal, entendido como puro (no condicional), se agregase un pacto (cfr. cap. XIV. § 5) dirigido a su resolución, sujeto éste a condición suspensiva. Soluciones a las cuales los romanos eran, por un lado, arrastrados, y por el otro ayudados por el dualismo entre derecho civil y derecho pretorio, que hacía que un negocio perfecto según el primer sistema pudiese ser anulado por el concurso de reglas propias

del segundo. Veremos posteriormente algún ejemplo de las construcciones jurídicas señaladas.

Tienen origen romano las distinciones entre condiciones *afirmativas* y *negativas*, según que se contemple la realización o no realización de un hecho (*si navis ex Asia venerit — si... non venerit*); y entre *potestativas*, *casuales* y *mixtas* (JUSTINIANO, C, 6, 51, 1 § 7), según que la realización del evento dependa de la voluntad de uno de los interesados⁸ o del azar (al cual está equiparada la voluntad de un tercero) o de un complejo de circunstancias en el cual estén en juego voluntad y azar.

Del hecho de que el acontecimiento impuesto como condición deba ser futuro e incierto se desprende que muchas cláusulas, aun teniendo apariencia de condiciones, no lo son: de donde proviene el nombre de condiciones *impropias*. Tales son, ante todo, los acontecimientos futuros pero no inciertos (así la condición “si Ticio muriera”, incierta solamente en lo que se refiere a la fecha); su inclusión en un negocio queda sujeta a las reglas del término. Opuesto es el caso de las condiciones *imposibles*, respecto de las cuales es objetivamente cierto que el acontecimiento no se verificará (ej.: *si coelum digito tetigeris*). Por regla general, el negocio sujeto a condición imposible es nulo; pero los sabinianos hicieron prevalecer, sólo para los actos de liberalidad por causa de muerte (institución de heredero, legado, fideicomiso; en el derecho justiniano también la manumisión testamentaria), la regla de que la condición imposible se considera como no impuesta: la razón de la desviación consistió, quizá, en considerar, en la duda, que el testador no haya tenido conciencia de la imposibilidad, y en no poderse reparar aquélla con una nueva y menos equívoca disposición⁹. A las condiciones imposibles quedan equiparadas en el derecho justiniano las ilícitas y las deshonestas, entendién-

⁸ Por lo común, la condición potestativa está en relación con la voluntad de quien se beneficia con el negocio (por ejemplo, donatario o legatario); pero no faltan hipótesis en las que está en relación con la voluntad del obligado. Un reglamento particular tiene la llamada condición meramente potestativa, que se tiene cuando se atiende no a un hecho dependiente de la voluntad, sino a la mera voluntad de cumplir la obligación o de aceptar la ventaja: si se trata de obligación, el negocio es nulo; si se trata de ventaja, la condición es impropia (*condicio iuris*).

⁹ Sobre la materia, cfr. los dos estudios de SCIALOJA, en “Bull. Ist. Dir. Rom.”, VIII, 1896, ps. 36 y ss., y XIV, 1902, ps. 5 y ss. (= *Studi giur.*, II, ps. 33 y ss., y 161 y ss.).

dose por tales no sólo aquellas en que se trate de hechos contrarios al derecho o a la moral, sino también las que puedan influir sobre una determinación de voluntad que el ordenamiento jurídico quiere libre (por ejemplo, la condición de dar el voto a Ticio); en la época clásica, la nulidad de ciertos negocios sujetos a semejantes condiciones resultaba de leyes especiales o de la aplicación de diversos principios, mientras que respecto de las condiciones deshonestas impuestas a disposiciones de última voluntad, una *remissio* concedida a los interesados por el pretor servía para mantener en pie el acto de liberalidad¹⁰.

Impropias son, también, las condiciones *in praesens vel in praeteritum conlatae* (D. 28, 3, 16) que se presentan cuando el acontecimiento se ha producido ya, o está en curso de producirse, y sea, en consecuencia, objetivamente cierto, aunque pueda ser subjetivamente ignorado; estas pseudocondiciones se parecen a las condiciones propiamente dichas en que los efectos jurídicos se producen solamente si el hecho se ha cumplido de conformidad con la cláusula, pero se distinguen de ellas por la falta de todas aquellas consecuencias que veremos derivar de la pendencia¹¹. En fin, son impropias, y se consideran no incluídas, las condiciones tácitas o *condiciones iuris*, consistentes en hacer objeto de particular relieve a un presupuesto fijado por el ordenamiento jurídico: por ejemplo, instituyo heredero a un extraño si *acceptare*, doy bienes en dote si se celebrare el matrimonio, etc.

Casi todos los negocios pueden ser objeto de condiciones propias; se exceptúan, sin embargo, los negocios solemnes del antiguo *mos maiorum*, los llamados *actus legitimi*, entre los cuales el Digesto (50, 17, 77) enumera la *acceptilatio*, la *servi optio*, la *datio tutoris*; en el texto originario debían estar incluídas la *mancipatio* (sustituída por la *emancipatio*) y la *cretio* (trasformada en *aditio hereditatis*), no menos que la *in iure cessio*.

Con relación a los efectos del negocio jurídico condicional, y comenzando por las condiciones suspensivas, corresponde dis-

¹⁰ Cfr. sobre el particular: DE RUGGIERO, *Sul trattamento delle condizioni immorali e contra leges*, en "Bull. Ist. Dir. Rom.", xvi. 1904, ps. 162 y ss.

¹¹ Entran en la misma categoría también aquellas condiciones, puestas en un testamento, cuya suerte se decidirá en vida del testador o en el momento de su muerte, es decir, antes del tiempo en que el testamento está destinado a tener efecto (por ejemplo, dejo 100 a mi servidor, siempre que me asista hasta mi muerte).

tinguir dos períodos: aquel durante el cual es incierta la verificación del evento (pendencia de la condición), y aquel otro en que sobreviene un estado de certeza, por haberse verificado la condición o por haberse excluido para siempre la posibilidad de que se verifique: a la primera hipótesis es equiparada aquella en que la verificación del evento es impedida por la parte que tenía interés en contrario¹². La estructura del negocio jurídico condicional tiene, en efecto, esto de característico: que las modificaciones a producirse en las relaciones jurídicas existentes son predisuestas, pero dejadas en la duda; de manera que solamente en un momento posterior aquellas modificaciones podrán producirse o quedar asegurada la permanencia del *status quo ante*. De ahí el gravísimo problema legislativo de hacer que el período de la pendencia no cause perjuicio a ninguno de los intereses opuestos, de modo que de la certeza sobreviniente puedan desprenderse todas las consecuencias.

Un sistema que en parte deriva del derecho justiniano, pero que en parte se ha completado con la evolución que el derecho ha experimentado de los glosadores en adelante, resuelve el problema haciendo que ningún acto de disposición sobre el bien que es objeto del negocio jurídico condicional disminuya la expectativa de quién tiene interés en que la condición se verifique, y dando a la certidumbre derivada de la verificación o no verificación de la condición una eficacia retroactiva en el sentido de que ella produzca sus efectos desde el día en que el negocio jurídico tuvo lugar (*ex tunc*, se suele decir, antes que *ex nunc*).

El derecho romano clásico (y en alguna parte también el justiniano) nos presenta, en cambio, un régimen en devenir, y una multiplicidad de reglas particulares difíciles de resumir bajo un concepto único; además, las decisiones particulares de la antigua jurisprudencia están tan a menudo turbadas por interpo-

¹² Sobre este caso de cumplimiento ficticio de la condición y sobre otros dos análogos (que el cumplimiento de una condición potestativa haya sido impedido por fuerza mayor, o por la mala voluntad del tercero de quien era necesaria la colaboración) se discute mucho entre los autores, sobre todo para distinguir las soluciones clásicas de las justinianas: cfr. BESELER, "Rev. Fundac. Savigny", 47, 1927, p. 359; GROSSO, *La finzione di adempimento nella cond.*, Modena, 1930; DONATUTI, *Sull'ademp. fittizio delle cond.*, en "Stud. et Docum.", 3, 1937, ps. 63 y ss.

laciones salteadas y confusas que constituyen para los intérpretes un torbellino de controversias¹³.

Ciertamente, es visible la tendencia a excluir, durante la pendencia de la condición, todas las consecuencias que tendría el correspondiente negocio incondicional: por ejemplo, el titular de un crédito condicional no está incluido entre los *creditores*, y se excluye a su respecto la aplicación de gran parte de las normas relativas a los derechos de crédito¹⁴; y en todo estadio de evolución del derecho romano (como por otra parte también en el derecho actual) el legado condicional solamente tiene efecto si la condición se cumple en vida del legatario. Sin embargo, es peligrosa la tendencia a hacer hincapié en estas reglas para deducir de ellas un principio uniforme, aplicado por la jurisprudencia clásica en todas sus consecuencias; así, no parece lograda la demostración de que los créditos condicionales nacidos de negocios *inter vivos* fuesen, también, intrasmisibles¹⁵.

¹³ Una exposición fundamental nueva, basada sobre un amplio examen de las fuentes, está en MITTEIS, *Römisches Privatrecht*, I, ps. 172 y ss., en gran parte seguido por RABEL, *Grundzüge*, ps. 501 y ss.; la posterior monografía de VASSALLI (*Dies vel condicio*, en "Bull. Ist. Dir. Rom.", 27, 1915, ps. 182 y ss.) llega sobre muchos puntos a resultados nuevos y persuasivos (para algún ejemplo, cfr. la nota siguiente), pero tiene otras veces el error de querer imponer a la jurisprudencia romana la admisión de consecuencias que en esta materia le eran extrañas. Cfr., por último, para la profundización de toda una serie de problemas, WIEACKER, *Lex co. amissoria*, Berlín, 1932; y LEVY en los *Symbolae Friburgenses in hon. O. Lenel*, 1933, ps. 108 y ss.

¹⁴ Entre otras cosas VASSALLI demuestra: 1º) que la *lex Cornelia de sponsu*, donde está prohibido asumir garantía en el mismo año y en favor de la misma persona por suma superior a los 20 mil sestercios, no se aplicaba a las deudas condicionales; 2º) que el acreedor condicional no podía pedir que se le pusiese en posesión de los bienes del deudor fallido (cfr. SÓLAZZI, *Scritti in onore di G. P. Chironi*, I, ps. 581 y ss.); 3º) que concurrendo sobre la misma cosa dos hipotecas, constituida una en garantía de una deuda pura y la otra de una deuda condicional, el grado de esta última se determina con relación a la fecha en que la condición se verifica, no a la del negocio constitutivo.

¹⁵ Cfr. de VASSALLI, además del citado *Dies vel condicio*, también *L'origine della trasmissibilità ereditaria dei crediti e dei debiti condizionali*, en "Riv. It. per le Sc. Giur.", 56, 1915, ps. 195 y ss. No niego que algún texto parece interpolado en esta dirección: en particular la última parte de *Inst.*, 3, 15, § 4, despierta sospecha, sea por el recurso al concepto de *spes*, sea por la falta de vinculación con cuanto precede. Pero sobre la derivación clásica de *Inst.*, 3, 19, § 25, no encuentro elementos de duda, y en D. 18, 6, 8 pr., la interpolación de las palabras *quasi iam contracta emptione in praeteritum* está precisamente demostrada, entre otras cosas,

Es cierto, por lo demás, que desde la época más antigua fueron dispuestas reglas dirigidas a hacer que el destinatario de la utilidad prevista en el negocio condicional no fuese perjudicado en la eventual adquisición por las medidas tomadas durante la pendencia. Las XII Tablas contemplaban el caso del *statuliber*, esclavo manumitido testamentariamente bajo condición¹⁶; y prohibían al heredero impedir de cualquier modo su verificación (por ejemplo: rehusándose a recibir la suma o la rendición de cuentas a que el *statuliber* estaba obligado). En cambio, si el *statuliber* hubiese sido transmitido a otro durante la pendencia, podía igualmente obtener su rescate cumpliendo la condición. Tales normas fueron aplicadas también a las otras relaciones condicionales; de donde resultan las reglas por las cuales: 1) todo negocio jurídico que disminuyera el valor de la adquisición si la condición se verificase, genera una responsabilidad personal para quien lo ha cumplido; 2) es eficaz, pero dejando intactas las expectativas que derivan del negocio condicional, todo acto de transferencia de la cosa debida; 3) la condición que ha fallado por obra de quien hubiera sufrido una pérdida con su cumplimiento, se tiene por verificada.

Lo que por derecho clásico falta del todo, y que sólo en el derecho justiniano comienza a abrirse camino a través de aplicaciones particulares, es el criterio de la retroactividad, pues por regla los efectos del negocio comienzan en el momento en que la condición se verifica; por eso, por ejemplo, quien tenía la disposición de la cosa no estaba nunca obligado a restituir los frutos de ella percibidos *pendente condicione*, y así también, si la cosa vendida ha perecido durante la pendencia de la condición, el comprador no debe pagar su precio como debería hacerlo si la venta fuese perfecta (cfr. p. 380).

Más incierto es el estado de las fuentes y de la ciencia en relación con los efectos de las condiciones resolutorias.

En los dos tipos más antiguos de cláusulas accesorias a la compraventa, aquella en virtud de la cual la cosa debe volver al

por la inelegante sutura con la frase que precede, hasta las palabras "*heredes quoque obligatus esse*", y esto me llevaría a excluir la derivación de todo el período de los compiladores (léase RICCOBONO-BOHACEK, "*Annali Sem. Palermo*", XI, 1924, ps. 332 y s.). En contra de VASSALLI también RABEL, "*Rev. Fundac. Savigny*", 47, ps. 465 y s.; y BESELER, "*Revue d'hist. du dr. (Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis)*", 1930, ps. 240 y ss.

¹⁶ Véase DONATUTI, *La statulibero*, Milano, 1940.

vendedor si dentro de cierto tiempo se le hace una oferta mejor (*in diem addictio*) y aquella por la cual el mismo efecto debe producirse si el comprador no paga el precio dentro del término (*lex commissoria*), se ha hecho hincapié primero en las distintas jerarquías de la propiedad y de la posesión, de manera que el goce, asegurado desde el primer momento al comprador, cedía al derecho del vendedor siempre que (y solamente en ese caso) hubiese tenido lugar la mejor oferta o que el precio no hubiese sido pagado¹⁷. Más tarde, semejantes cláusulas fueron interpretadas como pactos de resolución agregados al contrato consensual de compraventa, en sí perfecto; así, se podía también transmitir la cosa en plena propiedad, pero verificada la nueva oferta, o a falta de pago del precio, el vendedor intentaba la acción contractual para hacérsela restituir. En cambio, es inaplicable en el derecho clásico la *reivindicatio*, por la diferencia de estructura que los romanos ven entre los actos creadores de obligaciones (*contractus*) y los que transfieren la propiedad: solamente en el derecho justinianeo se abre camino la tendencia a considerar que con la verificación de la condición la propiedad vuelve automáticamente al vendedor, y que, en consecuencia, él puede reivindicar (es la llamada *eficacia real* de la resolución, contrapuesta a la *eficacia obligatoria* que ella tiene en la época clásica). Análogo desarrollo se ha verificado en los remedios concedidos al destinatario de una donación *mortis causa* (ps. 658 y ss.), cuando hubiese desaparecido el peligro en vista del cual se había hecho.

Un artificio jurídico distinto se registra en la llamada *cautio Muciana*. Si un legado está sujeto a una condición potestativa negativa tal que sólo pueda tenerse la certidumbre de su verificación a la muerte del beneficiario (por ejemplo, *si magistratum non ambieris*), la aplicación de los principios generales quitaría toda venta-

¹⁷ Para las *res Mancipi*, cuya propiedad no puede transferirse sino mediante *mancipatio* o *in iure cessio*, este resultado se alcanzaba haciéndole al adquirente bajo condición resolutoria la *simple traditio*, después de la cual el vendedor continuaba siendo propietario. Si el vendedor quería reivindicar la cosa, se lo impedía la *exceptio rei venditae et traditae* (cfr. cap. VIII, § 1); pero después de verificada la condición resolutoria, él podía contraponer a esta excepción la *replicatio doli*. Para las *res nec Mancipi*, el mismo resultado podía obtenerse considerando precaria la posesión que se transfería al comprador, con lo que la *traditio* no valía para hacerlo propietario.

ja al legatario, tanto más si se tiene en cuenta que, produciéndose la condición sólo a su muerte, el legado no se transmitiría tampoco a los herederos. De aquí un remedio, sugerido por el jurista republicano Q. MUCIO SCEVOLA, en virtud del cual el legatario entra inmediatamente en posesión de la cosa legada, obligándose mediante la forma de la estipulación (*cautio*) a restituirla si no se cumpliera la condición que se le impuso. Este régimen fué extendido por JUSTINIANO a las instituciones de heredero sujetas a análogas condiciones¹⁸.

*
* *

Se llama término (*dies*) a la cláusula de un negocio jurídico en virtud de la cual sus efectos se verificarán o dejarán de tener lugar en un día determinado o determinable. También el término puede, en consecuencia, ser suspensivo o resolutorio, *dies a quo* o *dies ad quem*, según la terminología de los viejos romanistas; los juristas romanos hablaban de disposiciones *ex die* o *in diem*.

El término difiere de la condición en cuanto no da lugar a ese estado de incertidumbre que es propio de la primera¹⁹; por consiguiente, mientras el crédito condicional no puede ser considerado como ya existente, la relación obligatoria a término es

¹⁸ Cfr. SCIALOJA, *Sulla c. M. applicata all'eredità*, en "Bull. Ist. Dir. Rom.", 11, 1899, ps. 265 y ss. (= *Scritti giur.*, II, ps. 128 y ss.); y véase ahora SOLAZZI, "Stud. e Docum.", 10, 1942, ps. 363 y ss. (contra: BIONDI, "Bull. Ist. Dir. Rom.", 49-50, 1948, ps. 241 y ss.).

¹⁹ Puede a veces suceder que esté expresado en forma de término un acontecimiento no sólo futuro sino también incierto; en estos casos, la forma no puede prevalecer sobre la sustancia, y por eso se aplican los principios de las condiciones (*Dies incertus pro condicione habetur*). En este orden de ideas, los viejos romanistas distinguían cuatro tipos de término: *Dies certus an certus quando* (p. ej., las calendas del próximo julio), *certus an incertus quando* (p. ej., el día de la muerte de Ticio), *incertus an certus quando* (p. ej., el día en que cumpla 80 años), *incertus an incertus quando* (p. ej., el día del nacimiento de mi primer biznieto). El *dies incertus an*, sea o no sea incierto también en el *quando*, se resuelve siempre en una condición; en cuanto al *dies certus an incertus quando*, si es impuesto a un legado, se tiene por derecho justiniano el mismo resultado, porque no pudiendo el legado tener efecto si el legatario ha muerto antes que se haga exigible, la disposición se entiende condicionada al hecho de que el evento se produzca durante su vida (diversamente por derecho clásico, según BESELER, "Rev. Fundac. Savigny", 45, 1925, p. 475).

perfecta, y el único efecto de la cláusula accesorio consiste en que no se pueda pretender el cumplimiento antes del *dies*; si el deudor paga antes, paga bien, y no puede pretender del acreedor la restitución.

No todos los negocios jurídicos pueden ser objeto de término suspensivo; antes bien, lo excluyen todos aquellos *actus legitimi* que, como se ha visto, no toleran las condiciones suspensivas, y lo excluye también la institución de heredero. Todavía más restringido es el campo de aplicación del término resolutorio: aparte de los negocios ya recordados, está excluido también de los actos de transmisión de la propiedad y de la constitución de servidumbre. Sus campos predilectos son, fuera de los negocios constitutivos de usufructo y de uso, los contratos que tienen la característica de ser concluidos por un tiempo más o menos rígidamente prefijado, como la locación y el comodato.

FRANJA

En el lenguaje justiniano (nunca, según parece, en el de los clásicos) se da el nombre de *modus* a la cláusula de un negocio jurídico a título gratuito, con la cual se impone al destinatario de la liberalidad la obligación de observar determinado comportamiento²⁰. Éste consiste, normalmente, en emplear en todo o en parte el activo patrimonial que se recibe, para fines de utilidad pública o en ventaja de personas extrañas al negocio.

Así entendido, el *modus* presenta no pocos puntos de contacto con la condición potestativa; sólo que mientras ésta suspende la eficacia del negocio, de manera que el destinatario de la liberalidad no puede gozar de ella si antes no ha cumplido la condición, la disposición modal es de actuación inmediata. Lo que importa una menor coercibilidad del comportamiento que el disponente exige de la contraparte; y tanto más en el derecho clásico, que no conoce un medio judicial que permita imponer en todos los

²⁰ Otras veces se habla de *modus* en el sentido normal de "medida", es decir, para indicar los límites dentro de los cuales un derecho está constituido: así, si se puede gozar de una servidumbre de pasaje solamente en determinadas horas, o de un acueducto en cierta estación.

casos la observancia del *modus*. Los remedios a que la práctica recurrió para obviar este inconveniente fueron diversos según que se tratara de legado, de institución de heredero o de donación.

Al legatario que se presenta ante el magistrado para obtener la entrega de las cosas legadas *sub modo*, éste puede negarle la acción si no se obliga mediante caución a restituirlas en caso de incumplimiento de la carga; remedio, sin embargo, que funciona solamente si el heredero demandado lo hace valer. Otras veces —en la época imperial— se ha buscado el remedio de considerar como fideicomisos los *modos* dispuestos en ventaja de personas preestablecidas; en esta hipótesis, los beneficiados gozan de aquellos remedios extraordinarios que a partir de Augusto permiten reclamar el cumplimiento de los fideicomisos.

El problema era todavía más difícil para los *modos* impuestos a las instituciones de herederos: cuando los herederos son varios, tiene lugar el juicio de división hereditaria (*actio familiae eriscundae*), en cuya ocasión ellos pueden exigirse recíprocamente oportunas cauciones; cuando es uno solo, el remedio lo da a veces el derecho público que reconoce a los magistrados, para el caso de las cargas que tienen en vista una ventaja pública, la facultad de intervenir aplicando multas a cargo del que deja de cumplirlas; y otras veces los testadores mismos buscan salvaguardarse creando intereses en conflicto con los del heredero, sea mediante la conminación de multas destinadas a las cajas públicas, sea disponiendo a cargo del heredero, para el caso de incumplimiento, la solemne desheredación, con designación de otro heredero o con el resultado de hacer acrecer con la cuota del que dejó de cumplir, las cuotas de los coherederos.

En materia de donaciones modales se debió recurrir a análogos medios indirectos. El medio más ampliamente usado fué la *fiducia*, es decir, la transmisión de la propiedad de la cosa donada con el acuerdo de que sería restituída si el *accipiens* no observase el comportamiento previsto; en tal hipótesis, el donante tenía la *actio fiduciae* (cfr. cap. xiv, § 2, n° 2). Otras veces el donante se hacía formular una promesa solemne en forma de estipulación. El derecho justiniano concede al donante *sub modo* los remedios que protegen los llamados contratos innominados (cap. xiv, § 2, n° 6); es decir, le ofrece la elección entre la *condictio causa data*

causa non secuta, para recuperar lo que ha transmitido, y la *actio praescriptis verbis* para exigir la ejecución del *modus*.

§ 3. LA REPRESENTACIÓN EN LOS NEGOCIOS JURÍDICOS

Normalmente, la voluntad manifestada en los negocios jurídicos pertenece a las mismas personas en favor y a cargo de las cuales se producen sus efectos. Pero existen excepciones múltiples, las que dan lugar a aquel conjunto de fenómenos que se indica con el nombre de *representación*²¹.

La representación puede ser necesaria (legal) o voluntaria. Tiene lugar la representación necesaria cuando la persona en quien se quiere que se produzcan los efectos del negocio es incapaz de obrar y debe, en consecuencia, ser reemplazada por otro sujeto capaz; los casos más típicos son, en el derecho romano, los del *curator furiosi* y del *tutor pupilli* (máxime si el pupilo es infante)²². Se tiene, en cambio, la representación voluntaria cuando una persona capaz de obrar se hace sustituir (o es, de hecho, sustituida) por otra en la realización de un negocio o en la gestión de una red más o menos amplia de negocios. Las hipótesis que aquí se presentan respecto de las relaciones entre representante y representado son múltiples, pero dos sobre todo ocupan el campo en el derecho justinianeo: el mandato y la gestión de negocios. Es mandatario el que se ha obligado por contrato a llevar a término determinado negocio en beneficio de otro (mandante); es gestor de negocios aquel que se ocupa útilmente de negocios de otro sin haber recibido el encargo de hacerlo. Investigaciones re-

²¹ Es necesario distinguir netamente de la representación la hipótesis en que se confía a un extraño la simple comunicación de una voluntad ya formada en el interesado. Es el caso del *nuncius*, que —como bien entendieron los romanos— no es más que un vehículo de manifestación de la voluntad, lo mismo que el discurso o la escritura. Esto importa que no en cualquier negocio pueda intervenir un *nuncius*, pues dondequiera que se exija para la manifestación de la voluntad una forma determinada, quien cumple la formalidad en interés de otro, tiene función de representante: solamente admiten un nuncio los actos exentos de formas, como los contratos consensuales y el divorcio.

²² Distinto es el caso de las personas jurídicas: en la ficción que hay en la base de su existencia jurídica, ellas son capaces de obrar, y los órganos a través de los cuales obran no son, en cuanto tales, sujetos extraños a los entes mismos.

cientes²³ hacen dudar de que sea precisamente ésta la concepción original de la gestión de negocios: parece más bien que al mandatario (normalmente extraño a la familia del interesado y encargado de un negocio determinado) se contrapusiese netamente el *procurator*, persona de categoría inferior y subordinado (por lo general un liberto), que administraba los bienes del ciudadano acaudalado en su totalidad o en una de las ramificaciones (geográficas o técnico-económicas) en que el patrimonio se dividía. En el derecho justiniano el *procurator* es, a veces, un mandatario o un *negotiorum gestor*, según que administre por encargo recibido o por propia iniciativa.

Para regular las relaciones entre los dos sujetos de la relación de representación, sea necesaria o voluntaria, y entre cada uno de ellos y la contraparte del negocio jurídico, son posibles dos sistemas:

a) que el representante obre *en nombre y por cuenta del representado*, en el sentido de que los efectos jurídicos del negocio se produzcan sin más en la persona del representado, y éste se haga titular de la propiedad que el representante ha adquirido, acreedor o deudor del tercero que ha contratado con el representante (*representación propiamente dicha, o directa*);

b) que el representante obre *por cuenta del representado*, pero *en nombre propio*, en el sentido de que los efectos jurídicos del negocio se produzcan exclusivamente en la persona del representante, haciendo de él un propietario, un acreedor o un deudor; pero con la salvedad de que, por efecto de la relación que liga a representante y representado (relación interna, que no repercute en el exterior), aquél puede exigir que se le releve de las pérdidas sufridas, y éste que se le invista con las ventajas económicas del negocio (llamada *representación impropia o indirecta*).

Principio fundamental del derecho romano es la exclusión de la representación directa. En consecuencia, si en cumplimiento de un mandato recibido de Ticio compro por su cuenta un esclavo, la *actio empti* me corresponde a mí contra el vendedor y la *actio venditi* al vendedor en mi contra, y en mi favor deberá ser cumplido el acto de transmisión de la cosa; luego, yo tendré que retransmi-

²³ FRESE, *Mélanges Cornil*, 1926, 1, ps. 325 y ss., y *Studi Bonfante*, 4, ps. 397 y ss. Cfr. sobre el tema el cap. xv, n° 3, donde se intenta una mediación entre la nueva tesis y la *communis opinio*.

tir la cosa a Ticio, y él deberá reembolsarme el precio o tomar a su cargo la obligación hacia el vendedor, pretensiones que encontrarán su forma jurídica en las acciones recíprocas de mandato. Igualmente ocurre si el tutor compra y vende, da o toma en arrendamiento en interés del pupilo, con la salvedad de que a las acciones de mandato se sustituyen, en las relaciones internas, las de tutela.

Pero en la exclusión de la representación directa no faltaron compensaciones y temperamentos que permitieran evitar las consecuencias perniciosas que de otra manera habría tenido en las relaciones comerciales²⁴. Conviene ante todo tener presente que, al fin de la época republicana y en los primeros siglos del Imperio, la necesidad de recurrir en los negocios a la actividad de extraños no era muy frecuente: la mayor parte de las veces bastaba la actividad de los sujetos a la potestad del *pater familias*, descendientes o esclavos (cfr. ps. 56 y 65). Puesto que toda adquisición del hijo o del esclavo es por derecho una adquisición del padre, se producían en estos casos, tanto para la propiedad como para los derechos de crédito, resultados idénticos a los que habría producido la representación directa. No se producía el mismo efecto, en principio, para las deudas contraídas por el esclavo o por el hijo de familia; pero un sistema de acciones, llamadas *adiecticiae qualitatis*, hacía que el *pater familias* quedase obligado, siempre que la deuda derivara de negocios que él hubiera autorizado o de los que sacara alguna ventaja. Él respondía por la totalidad de la deuda si había autorizado al tercero a contratar con el sujeto a potestad (*actio quod iussu*) o si había puesto al hijo o esclavo al frente de un comercio marítimo (*actio exercitoria*) o terrestre (*a. institoria*), para las necesidades del cual hubiese sido contraída la deuda; respondía en los límites del peculio, si el sujeto a potestad estaba provisto de él (*a. de peculio*), y con un poco más de rigor si le había consentido hacerlo objeto de especulaciones comerciales (*a. tributaria*); respondía, en fin, en los límites en que el producto del negocio de donde derivaba la deuda, había sido invertido en gastos necesarios para su hacienda doméstica (*a. de in rem verso*).

²⁴ Por último, sobre el asunto: RICCOBONO, "Annali Semin. Giur. Palermo", 14, 1930, ps. 389 y ss.; BETTI, "Bull. Ist. Dir. Rom.", 41, 1933, ps. 178 y ss.; RABEL, *Atti Congr. internaz. Dir. Rom.* (Roma), 2, ps. 235 y ss.

En algún caso, las acciones *adiecticiae qualitatis* fueron extendidas a relaciones de representación existentes, no ya entre el *pater familias* y los sometidos a su potestad, sino entre extraños; en efecto, las acciones *exercitoria* e *institoria* son otorgadas también si el capitán de la nave o el encargado del comercio terrestre no están sujetos a la potestad del principal. Más controvertida, pero en el estado actual de nuestros conocimientos bastante probable, es la clasicidad de la acción *quasi institoria*, otorgada contra el interesado en razón del contrato celebrado por el *procurator*²⁵. En estos casos, es evidente la admisión de la representación directa.

Otras veces, la derogación a la exclusión de la representación directa tiene su razón de ser en una potestad personal reconocida a los representantes sobre los incapaces. El *tutor pupilli* y el *curator furiosi* eran originariamente, más que gestores de una función de carácter público y de tendencias altruistas, titulares de un poder que se ejercía en especial ventaja de la familia, de la cual ellos eran, como parientes más próximos, los miembros más directamente interesados. En este orden de ideas, debieron serles reconocidos amplios poderes de disposición: con relación a la tutela, que muy pronto adquirió una nueva estructura más aproximada a la concepción moderna, queda de ellos quizá el único recuerdo en la facultad de *lege agere pro tutela*, que se señala como uno de los raros casos de representación admitidos en el proceso más antiguo; el *curator furiosi*, en cambio, que conservó por más tiempo el antiguo poder, tiene todavía en la época clásica funciones de representación directa, tanto que puede hasta ser parte en una *mancipatio* en interés del demente. Por otra parte, el derecho pretorio aceptó, dentro de ciertos límites, la tendencia a admitir una representación directa del pupilo por parte del tutor; y concedió muchas veces al pupilo acciones útiles (cfr. cap. IV, § 2) por actos y hechos del tutor²⁶.

²⁵ Esta acción es considerada justinianeana por BONFANTE, *Ist.*, 10ª ed., p. 177, y más decididamente por ALBERTARIO, *L' a. quasi institoria* (1912), y por CARRELLI, *Studi in mem. di B. Scorza*, Roma, 1940, ps. 143 y ss. Contra: SOLAZZI, "Bull. Ist. Dir. Rom.", 23, 1911, ps. 148 y ss., y RABEL, *Festschrift für Zitelman* [Estudios en honor de Zitelman], 1913.

²⁶ Cfr. SOLAZZI, *Le azioni del pupillo e contro il pupillo per i negozi conclusi dal tutore*, en "Bull. Ist. Dir. Rom.", 22, ps. 5 y ss.; 23, ps. 119 y ss.; 24, ps. 116 y ss.; 25, ps. 89 y ss.

Otras veces la brecha es abierta con relación a instituciones especiales, que aun sin ser negocios jurídicos producen, sin embargo, consecuencias jurídicas. Es el caso de la adquisición de la posesión: siendo, en efecto, la posesión, un señorío de hecho sobre la cosa, el acto por el cual ella se adquiere es una manifestación (por lo general, implícita) de voluntad, pero no un negocio jurídico, en cuanto no produce ni adquisición, ni modificación, ni pérdida de derecho subjetivo; y esto ha facilitado la derogación del principio que excluye la representación directa. En consecuencia, la posesión no sólo se adquiere por intermedio de los sujetos a la potestad del *pater familias*, sino también por obra del *procurator omnium bonorum*, y aun cuando el representado ignora el acto de adquisición. Más ampliamente se admite que la posesión de una cosa determinada pueda adquirirse encargando a otro que nos sustituya en la aprehensión material (caso que, por otra parte, se parece más al del *nuncius* que a la representación). Un desarrollo ulterior ha llevado a aplicar la representación a negocios jurídicos propiamente dichos, que en la estructura material coinciden con los modos de adquisición de la posesión; tal es en particular la tradición, que mientras sirve para transmitir la propiedad de las cosas *nec mancipi*, se cumple mediante la entrega de la cosa. Es, sin embargo, bastante incierto el problema acerca de la determinación de la parte en que el vínculo de la adquisición de la posesión con el de la propiedad pertenece al derecho clásico o es fruto de reelaboración posclásica y justinianeas²⁷.

§ 4. VOLUNTAD Y MANIFESTACIÓN.

LOS VICIOS DE LA VOLUNTAD: ERROR, DOLO, VIOLENCIA

Hemos supuesto hasta aquí la hipótesis normal, en la cual la manifestación corresponde exactamente a la voluntad del declarante, y ésta se determina en él libremente, sobre la base de una exacta valoración del contenido práctico del negocio jurídico en

²⁷ Cfr. sobre el tema, con resultados divergentes, MITTEIS, *Römisches Privatrecht*, I, ps. 210 y ss.; SOLAZZI, *Di alcuni punti controversi nella dottrina dell'acquisto del possesso per mezzo di rappresentanti*, en la "Memorie Accad. Modena", 1911; ALBERTARIO, *Lez. di dir. rom.*, Camerino, 1912-1913, ps. 133 y ss.; LEWALD, "Rev. Fundac. Savigny", 34, 1913, ps. 449 y ss.

formación. Pero estos supuestos no se verifican en todos los casos; al contrario, puede ocurrir que la manifestación no corresponda a una voluntad real, o que a la determinación del querer le falte la necesaria libertad o el conocimiento preciso del fin a alcanzar. En tal eventualidad, se plantea al ordenamiento jurídico el problema de la eficacia o ineficacia del negocio. Más precisamente, puede ocurrir que por una u otra de las circunstancias expuestas, el negocio se reduzca a una mera apariencia, de modo que las partes puedan y el juez deba considerarlo como si nunca hubiera nacido (*inexistencia*, o *nulidad* en sentido estricto); y puede también suceder que el ordenamiento jurídico considere al negocio como productor de efectos, pero ofrezca al interesado un arma (acción o excepción) con la cual pueda, si así lo desea, provocar su anulación o eliminar sus consecuencias (*anulabilidad*, comprendida también en la denominación de *nulidad* en sentido amplio).

En derecho romano, la que nosotros llamamos anulabilidad es más bien el obstáculo que normas más recientes y evolucionadas oponen a la realización de negocios en sí perfectos; lo que ocurre primero con el contraste entre la costumbre y las leyes que limitan sus abusos, más tarde y con mayor frecuencia con el contraste entre derecho civil y pretorio. En general, el antiguo derecho civil conoce sólo dos posibilidades: que el negocio nazca perfecto y produzca todas sus consecuencias, o que no llegue siquiera a nacer. Por eso, cuando una más amplia valoración de las necesidades de la práctica hizo sentir la exigencia de privar de eficacia a ciertos negocios que el derecho civil consideraba perfectos, fué necesario satisfacer esta exigencia con los medios indirectos de la *lex* y del derecho pretorio. Sólo en el derecho justiniano, por la fusión que se va operando entre los varios sistemas de las normas clásicas, se comienza a considerar el conflicto desde el ángulo visual de la anulabilidad.

También desde otro punto de vista parece que se debe reconocer una diversidad de concepción entre el derecho clásico y el justiniano; y es en lo que se refiere a los modos y a los límites de la indagación de la voluntad a través de su manifestación o más allá de ella. Para los clásicos, las palabras y los gestos de las partes, aun cuando no estén fijados en fórmulas inmutables, son siempre interpretados según el criterio objetivo de la valoración que cada palabra o gesto encuentra en el ambiente social: la even-

tualidad de que el querer interno sea distinto del que resulta de tal investigación, es un riesgo de que el interesado debe saberse guardar, recurriendo, si lo cree necesario, a expertos. El derecho justinianeo, en cambio, está dominado por la tendencia a desentrañar escrupulosamente la voluntad manifiesta, y a tomar en consideración también circunstancias extrañas, con tal de captar a toda costa el querer interno del individuo; por eso, las interpretaciones objetivas atribuidas por los juristas clásicos a las distintas cláusulas de los testamentos y de los contratos que la práctica ponía bajo su vista, se hallan, la mayor parte de las veces, en el Digesto, interpoladas con la reserva de la eventual y diversa voluntad del particular testador o contratante; y por eso mismo la determinación de la categoría en que cada negocio debe ubicarse, no se efectúa más con relación a sus elementos objetivos, sino con referencia a la intención (*animus*) de los interesados: *animus contrahendi*, *donandi*, *intercedendi*, *legandi*, *novandi*, *transigendi*, *vendendi*, etc.²⁸.

La divergencia entre los dos criterios merece ser destacada por haber repercutido con particular insistencia en las modernas doctrinas del negocio jurídico. Hoy se contraponen, en efecto, una teoría de la voluntad según la cual la manifestación es considerada como un mero trámite para el reconocimiento del querer —trámite que puede ser falaz y debe, en consecuencia, ser integrado con todos los otros medios que pueden investigarse con el querer interno—, y una teoría de la manifestación que sostiene que la misión del ordenamiento jurídico no consiste en dar actuación a

²⁸ El fenómeno ha sido ampliamente estudiado en la literatura reciente y sobre todo las interpolaciones que contienen la reserva de la eventual voluntad contraria de los disponentes (*nisi aliud testatorem sensisse evidenter appareat; si voluntas testatoris... evidenter non ostenderetur; nisi si heres de qua parte testator senserit evidenter probaverit*, etc.) están entre las más seguras. Para la oposición entre el pensamiento clásico y el bizantino véase especialmente PRINGSHEIM, *Animus donandi*, en "Rev. Fundac. Sav.", 2, 1921, ps. 273 y ss.; PARTSCH, *La doctrina del negocio simulado*, *ibid.*, ps. 227 y ss.; ALBERTARIO, *Studi Bonfante*, 1, ps. 609 y ss.; BERTI, *op. cit.*, ps. 222 y ss., 253 y ss.; KOSCHAKER, *Conferenze a ricordo di G. Castelli*, Milano, 1940, ps. 104 y ss. Es posible que para algunas aplicaciones los críticos hayan ido demasiado lejos, descuidando la posibilidad de que aquí y allí los juristas hubieran sido más amplios en la búsqueda del elemento intencional, designándolo también, eventualmente, con el nombre de *animus*; pero no parece destinada al éxito la cruzada emprendida en favor de la clasicidad del *animus*, aun cuando se apoye en la alta autoridad de RICCOBONO.

la voluntad privada, cualquiera que ella sea, sino en tutelar la expectativa de aquellos que han contado con esa manifestación, interpretándola según su valoración social. Es inútil poner de relieve cómo esta segunda teoría responde mejor a las exigencias de la vida de relación: los estudios más recientes muestran las influencias extrañas de que derivó, en el mundo bizantino, el dogma de la voluntad, fruto de la incauta recepción de doctrinas filosóficas moralizantes en el campo de la jurisprudencia.

*
* *
*

La divergencia entre manifestación y voluntad es sólo aparente cuando, por ejemplo, las palabras que normalmente sirven para expresar la voluntad en un negocio son empleadas por broma o con fines de enseñanza; no sólo falta en estos casos la voluntad, sino que, en rigor, también falta la manifestación, a la cual las circunstancias quitan la seriedad que de otra manera le es propia. Existe, en cambio, la divergencia, cuando una manifestación aparentemente seria tiene lugar con el fin de provocar el engaño de la contraparte de un negocio jurídico bilateral (*reserva mental*), o también para engañar de acuerdo entre las dos partes a terceros (*simulación*). En principio, la *reserva mental*, es decir, la preconstitución de una interpretación particular de palabras que en el uso común significan otra cosa, actúa en total menoscabo de quien lo hace, dejando intacta la eficacia de la manifestación. En cuanto a la *simulación*, se la distingue, ante todo, en *absoluta* (cuando se realiza la manifestación de voluntad conforme a determinado negocio, sin la voluntad de concluir ninguno: se finge, por ejemplo, comprar o vender, pero no se quiere la recíproca transferencia de la cosa y del precio) y *relativa* (cuando, mientras se realiza la manifestación de voluntad conforme al negocio A, se quiere, en cambio, el negocio B: se finge vender y comprar, pero se quiere donar y aceptar la donación).

Según los cánones del derecho justiniano, de los que se forman también la mayor parte de los sistemas jurídicos actuales, el negocio jurídico simulado no tiene efecto; pero puede tenerlo, en general, el negocio que verdaderamente se ha entendido realizar (disimulado): *plus valet quod agitur quam quod simulate con-*

capitur. Parece cierto que esta máxima no hubiera sido nunca formulada así genéricamente por la jurisprudencia clásica, pero puede considerarse que aun aislando uno del otro los casos prácticos y resolviéndolos según diversos principios, los juristas hubieran alcanzado, en el conjunto, resultados análogos a aquellos a que condujera más tarde el principio justinianeo²⁹. Pero no siempre las consecuencias examinadas se verifican en la práctica, porque a menudo las partes recurren a la simulación, precisamente cuando una prohibición legal les impediría realizar el negocio que disimulan, o cuando quieren evitar las formas por él requeridas; hipótesis en las cuales es evidente que el negocio disimulado, despojado de las vestiduras que los simuladores le han dado, se manifiesta nulo.

Mucho más interesantes son las hipótesis en que la voluntad, aun estando del todo conforme con la manifestación, es el efecto de un falso conocimiento o del engaño o violencia de otro.

FRANJA

Falso conocimiento es el *error*, ya recaiga sobre el objeto o sobre el destinatario de un negocio jurídico unilateral, o sobre la concomitante voluntad de la contraparte en un negocio bilateral; en esta última hipótesis, mientras las dos voluntades de

²⁹ Cfr. en diverso sentido, además del trabajo ya citado de PARTSCH, BETTI, *Dir. rom.*, I, ps. 275 y ss.; RICCOBONO, *Studi Bonfante*, I, ps. 156 y ss.; G. LONGO, *Studi Riccobono*, III, ps. 113 y ss., y "Arch. Giur.", 115, ps. 117 y ss., y 116, ps. 35 y ss. (1936); PUGLIESE, *Simulaz. nei neg. giur.*, Padova, 1938.

Con el negocio simulado, que es un recurso elegido por las partes para ocultar sus verdaderos fines, no deben confundirse aquellos negocios ficticios que el ordenamiento jurídico crea, empleando con fines nuevos y diversos los formularios ya predispuestos para otros negocios. Los romanos usan, a este propósito, el adjetivo *imaginarius* (p. ej., definen la *emancipatio* clásica como *imaginaria venditio*), o bien afirman que una forma dada es usada *dicis causa* (por modo de decir, esto es, en apariencia). Quien vende tres veces el hijo a un extraño para liberarlo de la patria potestad (*emancipatio*), quien reivindica como propia ante el magistrado la cosa que quiere adquirir (*in iure cessio*), no sólo no quiere vender ni reivindicar nada, sino que ni siquiera lo simula; más bien se vale de formas de las que el ambiente social conoce exactamente el alcance práctico, aun cuando éste sea diverso de lo que las palabras y los gestos empleados significan precisamente.

las que el negocio debería ser la resultante, parecen converger, son en realidad tan divergentes que representan más bien una discrepancia que un consenso. Los casos más típicos, según las clasificaciones adoptadas por la ciencia medieval y moderna³⁰, son los siguientes:

1) El *error in negotio*, que tiene lugar cuando las partes no están de acuerdo sobre el acto a cumplir; así, si Ticio da una suma a Cayo con intención de donársela, mientras que Cayo la acepta como si le fuese entregada en mutuo, no hay ni donación ni mutuo, y la obligación de restitución que pesa sobre Cayo tiene su fundamento en el simple hecho de que la propiedad de la suma ha pasado a él sin una causa que lo justifique.

2) El *error in persona*, que tiene lugar cuando se concluye el negocio con una persona distinta de aquella con la que se entendía contraerlo. Esta especie de error no tiene la misma significación en todos los casos, pues solamente puede considerarse causa de inexistencia respecto de aquellos negocios en que la persona de la contraparte tiene importancia particular; por ejemplo, para todos aquellos que se fundan sobre el crédito, o sobre una especial competencia.

3) El *error in corpore*, que tiene lugar cuando, siendo el objeto del negocio una cosa que las partes creen haber determinado, ellas han pensado, en realidad, cada una, en una cosa diversa; si mientras Ticio me mostraba desde lo alto de una torre el fundo que entendía arrendarme (*traditio longa manu*), yo hubiera seguido mal su gesto, volviendo mi atención y mi voluntad hacia otro fundo; o si tratando con Cayo la compra de uno de sus esclavos ausentes, hubiera entendido comprar un esclavo distinto de aquel (por ejemplo, del mismo nombre) que él entendía venderme.

Mientras para los negocios jurídicos formales y para la estipulación especialmente, no parece que los juristas hayan reco-

³⁰ También aquí el derecho romano clásico nos ofrece solamente la resolución de algunos problemas prácticos, partiendo casi siempre del reconocimiento del disenso. Algunas de las denominaciones de los varios tipos de error, y particularmente la del *error in corpore*, se encuentran en nuestras fuentes, pero en textos probablemente interpolados y, en todo caso, con significados oscilantes. Sobre el tema, varias veces rozado también por BESELER y por LENEL, cfr. LAURIA, *L'errore nel diritto romano*, en "Riv. di Dir. Civile", 1927, ps. 313 y ss.; y VOCI, *L'errore nel diritto romano*, Milano, 1937.

nocido importancia a otros errores que los ya recordados, en el contrato consensual de compraventa, que por estar fundado sobre la buena fe exige una más perfecta correspondencia en la voluntad de las partes, surge, por lo menos entre los juristas de época más avanzada, la figura particular del *error in substantia*, que tiene lugar cuando, aun habiendo acuerdo sobre la individualización de la cosa, se está sin embargo en desacuerdo sobre sus características esenciales y constantes; así, si yo creyese de oro un objeto que es de plata, o si creyese varón al esclavo que es mujer. El sentido preindicado de *substantia* explica cómo las soluciones se apartan de aquellas a las que conduciría la apreciación económicosocial; no sólo explica cómo no se atribuye importancia al error sobre la virginidad de la esclava (D. 18, 1, 11 § 1), sino también cómo, respecto de quien haya comprado vinagre creyéndolo vino, distinga ULPiano (l. 9 § 2 h. t.) según se trate de vinagre artificial o de vino agrio, y sólo reconozca un error sustancial en la primera hipótesis. Hasta la sorprendente decisión (l. 14 h. t.) que reconoce válida la compra de un objeto dorado como si fuera de oro, "quia auri aliquid habuit", está justificada por la consideración de que aquel tanto de oro es inseparable del objeto. Fuera de los casos en que concurre la idea de la *substantia*, se tiene el *error in qualitate*, que para los clásicos no tiene importancia jurídica, mientras el mismo derecho justiniano muestra sólo una tímida tendencia a conceder al comprador una acción de disminución del precio³¹.

Hemos tratado hasta aquí del error considerado como una causa de ineficacia del negocio jurídico, pero los efectos del error pueden también orientarse en dirección opuesta, removiendo obstáculos que de otra manera impedirían su eficacia. Casos típicos de esta especie son: la validez del mutuo de dinero hecho a un hijo de familia, no obstante la prohibición del senadoconsulto Macedoniano, cuando el comportamiento del mutuuario y la consideración social que lo circunda sean tales que lo hagan considerar razonablemente un *pater familias*; la validez del testamento en que intervenga como testigo un esclavo, cuando la opinión común

³¹ Cfr. el texto interpolado de D. 19, 1, 21 § 2, donde se discutía en el origen una hipótesis de dolo; y sobre todo el problema del *e. in subst.*, PARTSCH, *Aus nachgelassenen und kleineren verstreuten Schriften* [Escritos inéditos y raros], Berlín, 1931, ps. 47 y ss.

lo sindique como un hombre libre; y aunque la hipótesis no sea de negocio jurídico propiamente dicho, el *erroris causa probatio*, sobre cuya base la mujer romana que se ha unido en matrimonio con un extranjero consigue no sólo que las nupcias sean reconocidas como válidas, sino que el marido y los hijos adquieran la ciudadanía. En este orden de ideas, puede ser invocado por ciertas categorías de personas (por ejemplo, soldados, menores de edad mujeres), también el error de derecho, es decir, el que se refiere al contenido de las normas jurídicas vigentes: por lo común, vale también por derecho romano el principio de que el error de derecho no excusa.

*
* *
*

También hay sustancialmente error cuando un acto jurídico se dice viciado por *dolo*. Éste consiste, en efecto, en el comportamiento malicioso de una de las partes que en un negocio jurídico bilateral hace incurrir en error a la otra. Por lo tanto, si el error se ha producido por el dolo, y es por sí mismo tal que determine la nulidad del negocio, el hecho de que haya sido provocado por dolo no modifica la situación. Pero la exigencia social de la defensa del individuo contra el engaño de otro, hace que también ciertos errores, que por sí mismos no podrían influir sobre la validez del acto, lo hagan en cambio atacable cuando son determinados por dolo: sólo en tal sentido éste se hace objeto de una especial regulación jurídica. Más precisamente, el dolo puede hacer que también en los negocios formales sea tomado en consideración el *error in substantia*, y que adquiera importancia hasta el *error in qualitate*, toda vez que en él pueda verse el motivo determinante de la adhesión al negocio.

La represión del dolo fué una innovación pretoria respecto al *ius civile*; y es innovación que Cicerón nos describe como ocurrida ante sus ojos, por obra del jurista AQUILIO GALLO. Fueron entonces introducidas una *actio* y una *exceptio doli*: ejercible la primera por la víctima del engaño, cuando ha cumplido ya por su parte las obligaciones nacidas del negocio viciado, para obtener la restitución de lo que ha dado o una reparación del daño sufrido; oponible la segunda por la víctima misma llamada a juicio por la

contraparte que requiera el cumplimiento (así, si se me ha arrancado la promesa de dar cien y yo los he dado, puedo ejercer la *actio doli*; en cambio, si no los he dado todavía y el acreedor intenta contra mí la *actio ex stipulatu*, le opongo la *exceptio doli*).

La *actio doli* tiene carácter penal, con todas las consecuencias que derivan de tal carácter, primera entre todas, la intrasmisibilidad pasiva y la limitación del tiempo en que puede ejercerse, a un año; es también infamante (cfr. p. 68); pero, ya sea contra el heredero, o después del referido plazo de un año, el pretor concede una acción *in factum*, no penal ni infamante, dirigida al resarcimiento, o quizá sólo al enriquecimiento que el autor del dolo o sus herederos hayan obtenido con el negocio³².

Por su especial gravedad, la *actio doli* era concedida sólo con carácter subsidiario, es decir, que sólo podía intentarse a falta de todo otro remedio. En compensación, fué ampliamente extendida por la jurisprudencia, fuera de su primitivo campo de aplicación; es decir, no sólo cuando hubiese habido engaño en la conclusión del negocio jurídico, sino también en casos en los cuales una de las partes se hubiese comportado maliciosamente frente a la otra en el tiempo posterior, supuesta siempre la ausencia de otros medios judiciales; así, si he realizado para Ticio una obra determinada en vista de una contraprestación que me ha prometido y él no respeta la palabra empeñada, puedo hacerme resarcir del daño con la *actio doli*, aun cuando ningún engaño se haya empleado en perjuicio mío al realizarse el acuerdo (cfr. p. 354).

El mismo desarrollo se produjo, y en más amplia escala, con respecto a la *exceptio doli*, que fué concedida cada vez que el ejercicio de una acción por parte del derechohabiente representase, teniendo en cuenta las distintas relaciones y acuerdos existentes entre las partes, una evidente iniquidad. Es éste el sentido de la división que los romanistas formulan al distinguir una *exceptio doli speciali seu praeteriti* (fundada sobre el dolo cometido al tiempo de la conclusión del negocio jurídico) y una *exceptio doli generalis seu praesentis* (fundada sobre el dolo cometido en

³² Para la crítica de los textos relativos, cfr. ALBERTARIO, "Rend. Ist. Lomb.", 46, 1913, ps. 453 y ss.; y en sentido opuesto MAIER, *Prätorische Bereicherungsklagen* [Acciones pretorias de enriquecimiento], Berlin, 1932, ps. 35 y ss.

el momento actual, o sea aquel en que se intenta la acción): distinción bastante sutil y ciertamente deducida de la casuística de las fuentes²². La *exceptio doli*, como toda otra excepción, debe ser invocada explícitamente por el demandado en el primer estadio del proceso (*in iure*), y en consecuencia, inserta en la fórmula; salvo el caso de los *bonae fidei iudicia*, en los cuales, dada la obligación del juez de condenar en el "*quidquid dare facere oportet ex fide bona*", se tiene en cuenta el dolo, sea en el sentido técnico de vicio de la voluntad, sea en aquel significado más amplio que acabamos de examinar.

*
* *
*

Puede ocurrir que contra el autor de un negocio jurídico unilateral o contra una de las partes de un negocio bilateral, se ejerza violencia, sea por el mismo interesado o por persona que obre por cuenta de él. La doctrina romanista distingue dos tipos de violencia: *vis absoluta*, o violencia física, que consistiría en forzar materialmente al individuo a manifestar una voluntad que no es la suya (conduciendo, por ejemplo, la mano de quien escribe); y *vis compulsiva*, o violencia moral, consistente en amenazar a la víctima con un mal tan grave en su persona, integridad u honor, o en el de persona querida, como para inducir la a una voluntad que de otra manera no tendría. El primer tipo de violencia llevaría a la inexistencia del negocio jurídico, el segundo a su anulabilidad.

En verdad, en nuestras fuentes no se conocen vestigios de *vis absoluta*; quizá porque, siendo rarísima en Roma la forma escrita, la única que puede ser objeto de verdadera coacción física, no se estimó necesario tomarla en consideración. Y quizá no hay por qué excluir, no obstante tal silencio, que, colocados ante hipótesis en que el uso de la violencia hubiese eliminado totalmente el proceso formativo de la voluntad negocial, también los juristas romanos pudiesen declarar inexistente el negocio jurídico, como en los casos de *error in negotio* o *in corpore*. Ciertamente a la vio-

²² Las dos direcciones están ya claramente indicadas en el módulo de la *exceptio* (referido por GAYO, IV, 119): "*si in ea re nihil dolo malo Aulii Agerii factum sit neque fiat*". En cambio, es probable la interpolación total de D. 44, 4, 2, 5, cuyo concepto es diverso del anteriormente indicado y ciertamente no clásico (BESELER, *Contributi*, I, p. 107).

lencia moral, que llaman *metus* (el acto de infundir temor), le dan una importancia aparentemente demasiado escasa: la máxima "quamvis si liberum esset noluissem, tamen coactus volui" (D. 4, 2, 21 § 5) es algo severa con relación al agente, que en el fondo no ha querido realmente nada. De cualquier modo, sólo esta severidad de valoración puede explicar por qué el antiguo *ius civile* no tuvo para nada en cuenta el *metus*: laguna mucho más grave que la relativa al dolo, porque mientras la falta de reglas especiales que contemplaran este último podía en alguna parte ser suplida por el régimen del error, la manifestación de voluntad arrancada con violencia conservaba siempre su vida.

También aquí el nuevo régimen fué creado por el pretor, quien introdujo en favor de la víctima de la violencia tres remedios: la *in integrum restitutio*, la *actio quod metus causa gestum erit* (o simplemente *actio metus*) y la *exceptio* del mismo nombre. De los tres medios, el más antiguo, y el único para el cual se conservó la cláusula edictal expresa, es el primero, consistente en el acto del magistrado que, a instancias de la víctima y después de un examen de las circunstancias, rehusa los remedios judiciales que por estricto derecho corresponderían o concede aquellos que hubieran caducado, a fin de eliminar los efectos del negocio afectado de violencia. La persecución de la violencia fué vigorizada cuando, siempre en la época republicana, el pretor concedió la *actio metus*: ésta es concedida por el cuádruple de la prestación realizada o, en todo caso, del daño sufrido, y, por lo menos en el derecho justiniano, no sólo contra el autor de la violencia o la persona por cuya cuenta se ejerció, sino también contra los que sucesivamente hubieran adquirido la cosa que fué objeto del negocio jurídico viciado o que de cualquier modo hubiesen obtenido ventajas materiales derivadas de él, aunque fuese mediante contraprestación y de buena fe³⁴. Límite a la gravedad de tal per-

³⁴ Esto se expresa diciendo que la acción es *in rem scripta* (D. 4, 2, 9 § 8): lo que quiere decir que en la fórmula, si bien se menciona la violencia cometida, no se dice que haya sido cometida por el demandado. Igualmente ocurre con la excepción, que es también *in rem scripta* (D. 44, 4, 4 § 34): "si in ea re nihil metus causa factum est" (sin el nombre de Aulo Agerio que vimos estar mencionado en la *exc. doli*, *supra*, nota 33, como supuesto autor del dolo mismo). Insignes romanistas (SCHULZ, "Rev. Fundac. Savigny", 43, 1922, ps. 171 y ss.; concorde LENEL, *Edictum*, 3ª ed., p. 113) consideran que en derecho clásico la acción correspondiese solamente contra el autor de la violencia o persona por cuya cuenta